

第 4 部

商法

▶ 科目別ガイダンス	582
------------------	-----

第1章 商法	585
---------------------	-----

第1節 商法総則 ※	585
------------------	-----

第2節 商行為 ※	596
-----------------	-----

第2章 会社法	609
----------------------	-----

第1節 会社法総論	609
-----------------	-----

第2節 設立 ※	613
----------------	-----

第3節 株式 ※	621
----------------	-----

第4節 機関 ※	634
----------------	-----

第5節 計算	659
--------------	-----

第6節 持分会社	664
----------------	-----

第7節 組織再編	667
----------------	-----

※は『スタートダッシュ』掲載テーマです。

科目別ガイドンス

1 商法とは何か

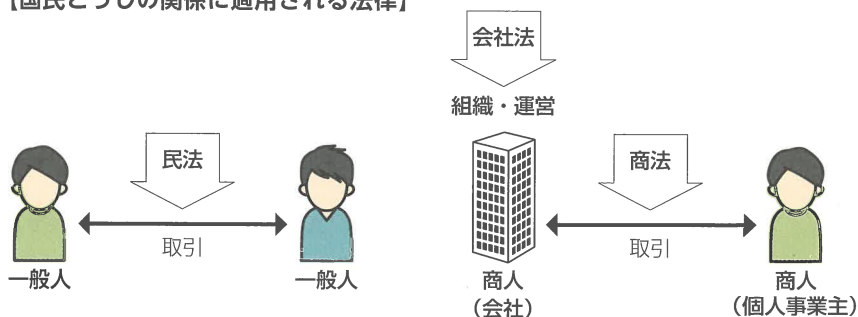
行政書士試験の商法では、**商法**と**会社法**という2つの法律が出題されます。

商法は、民法と同じく国民どうしの関係について定めている法律です。もっとも、民法は、一般市民どうしの取引を対象としているのに対し、商法は、**個人事業主や会社などの「商人」が営利目的（お金もうけ）で継続的に行う取引を対象**としています。そして、商法は、**民法の特別法**（民法に優先して適用される法律）であるとされています。

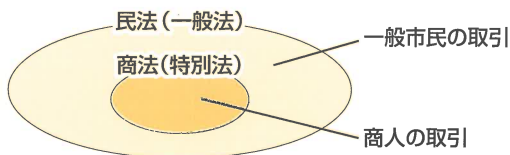
次に、会社法は、「商人」の中でも特に会社という形態をとるものについて規定している法律です。この会社法は、会社の組織・運営などについて定めています。

国民どうしの関係に適用される法律についてまとめると、以下のようになります。

【国民どうしの関係に適用される法律】



【民法と商法の関係】



2 出題傾向表

10年間（平成24年度～令和3年度）分の本試験の出題傾向を表にまとめました。

(1) 商法

	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
商法総則			○		○	○				○
商行為	○	○		○			○	○	○	

○：そのテーマから出題、△：肢の1つとして出題

(2) 会社法

	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
会社法総論						△			△	
設立	○		○	○	○	○	○	○	○	○
株式		○	○	○	○	○	○	○	○	○
機関	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
計算	△					△	○			○
持分会社					○					
組織再編	○									

○：そのテーマから出題、△：肢の1つとして出題

3 分析と対策

(1) 学習指針

行政書士試験の商法では、例年、商法から1問、会社法から4問出題されます。そこで、**会社法を中心に学習すべき**といえます。しかし、会社法は全部で1000条近くあるのに対し、商法は全部で150条程度しかありませんから、**商法も捨てずに学習しておくべき**といえます。

ただし、商法・会社法合わせて5問（20点）しか出題されない以上、**時間をかけすぎるとは禁物**です。特に、会社法については「**設立**」「**株式**」「**機関**」からの出題が**とても多い**といったように出題傾向に偏りがありますから、この3つのテーマを重点的に学習し、その他は一読して過去問を解く程度にとどめるといったメリハリを付けた学習が必要となるでしょう。

なお、仕事が忙しい、試験日がすでに迫っているなど、勉強時間が十分取れない人は、思い切って商法を捨てる（まったく勉強しない）という選択肢もやむを得ないと思います。

(2) 学習内容

商法・会社法は、**ほぼ全部が条文知識を問う問題**です。そこで、商法・会社法は、とにかく条文を読み込んでいきましょう。また、条文を図表で整理したり、条文の趣旨を押さえて記憶しやすくするといった工夫をしてみましょう。

なお、まれに判例知識問題も出題されますが、ほとんどの人は正解できないのであまり気にする必要はないでしょう。

(3) 得点目標

商法・会社法は、**4割正解**できれば十分でしょう。

【商法の得点目標】

出題形式	出題数	得点目標
5肢択一式	5問(20点)	2問(8点)

第1章 商法

第1節 商法総則

重要度 B



学習のPOINT

ここでは、商法全体に共通するルールについて学習していきます。条文からの出題がほとんどなので、条文をくり返し読み込んでおきましょう。

1 商法の適用範囲

商人の営業、商行為その他商事については、商法が適用されます（1条1項）。そこで、商法の適用対象となる「商人」「商行為」の意味を明らかにしていきます。※1 図28-36-1

(1) 商人

商人には、**固有の商人**と^{ぎせいしょうにん}**擬制商人**の2種類があります。

① 固有の商人

固有の商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者です（4条1項）。「**自己の名をもって**」とは、自分が権利・義務の主体となってということです。また、「**業とする**」とは、営利の目的をもって同種の行為を反復的・継続的に行うことです。図29-36-1

② 擬制商人

擬制商人とは、商行為をすることを業としていないものの、商人とされる者のことです。商法では、擬制商人として以下の2種類が認められています（4条2項）。図29-36-2

【擬制商人】

1	店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者 ※2
2	鉱業を営む者 ※3

※1 参考

当事者の一方のために商行為となる行為については、その双方に商法が適用される（3条1項）。

※2 具体例をイメージ

例えば、自ら収穫した野菜を売店で販売する者などである。

※3 具体例をイメージ

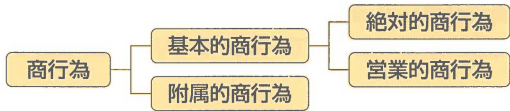
例えば、鉱物を採掘する者などである。

(2) 商行為

商行為には、誰が行っても商行為となる**基本的商行為**と、商人がその営業のためにする行為である**附属的商行為**（503条）があります。基本的商行為には、さらに**絶対的商行為**（501条）と**営業的商行為**（502条）の2種類があります。📖29-36-5

商行為の分類についてまとめますと、以下の図のようになります。

【商行為の分類のまとめ】



① 絶対的商行為

絶対的商行為とは、その行為の有する客観的な営利的性格から、当然に商行為となるもののことです。📖29-36-4

絶対的商行為は、501条が列举している以下の4種類の行為です。

【絶対的商行為】

投機購買及びその実行行為	利益を得て譲渡する意思をもってする動産・不動産・有価証券 ※1 の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為（安く買って高く売る行為） ※2 ※3 📖 3-36-ア
投機売却及びその実行行為	他人から取得する動産・有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為（高く売った後に安く買う行為） ※4 📖 3-36-オ
取引所においてなされる取引	株式などの金融商品の取引を目的とする金融商品取引所などにおける取引
手形その他の商業証券に関する行為	振出し ※5 うらがき 裏書 ※6 ・保証などの証券上の行為

② 営業的商行為

営業的商行為とは、営業目的で反復・継続してなす場合にはじめて商行為となるもののことです。

営業的商行為は、502条が列举している以下の13種類の行為です。 ※7

※1 用語

有価証券：財産権が存在することを表している証券であって、その権利の発生・移転・行使が証券をもってなされることが必要とされているもののこと。例えば、手形や小切手などである。

※2 具体例をイメージ

例えば、小売店が商品を仕入れて客に販売することなどである。

※3 重要判例

「取得したものの譲渡」とは、取得したものをそのまま譲渡することのみならず、製造・加工して譲渡する場合を含む（大判昭4.9.28）。📖 3-36-イ

※4 具体例をイメージ

例えば、先物取引などである。

※5 用語

振出し：手形・小切手を発行すること。

※6 用語

裏書：証券を譲渡すること。

※7 参考

もっぱら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務を提供する行為は、営業的商行為に当たらない（502条ただし書）。

【営業的商行為】

投機貸借及び その実行行為	賃貸する意思をもってする動産・不動産の有償取得・賃借又はその賃借したものの賃貸を目的とする行為 ※8 図 3-36-エ
他人のための製造・ 加工に関する行為	材料に労力を加えることを有償で引き受ける行為 ※9
電気・ガスの供給に 関する行為	電気・ガスを供給することを有償で引き受ける行為
運送に関する行為	物・人を場所的に移動させること（運送）を引き受ける行為
作業・労務の請負	道路・建物の建設・建築や労働者の供給を請け負う行為
出版・印刷・撮影に 関する行為	文書などを印刷して販売することや印刷・撮影を引き受ける行為 図 3-36-ウ
しょうおく 場 屋取引	客に一定の設備を利用させることを目的とする取引 ※10
両替その他の銀行取引	金銭・有価証券を受け入れたり給付したりする行為
保険	対価を得て保険を引き受ける行為
寄託の引受け	他人のために物の保管を引き受ける行為 ※11
仲立ち・取次ぎに 関する行為	他人間の法律行為の媒介を引き受けること（仲立ち）や、自己の名をもって他人の計算において法律行為をするを引き受けること（取次ぎ） ※12
商行為の代理の引受け	本人にとって商行為である行為の代理を引き受けること ※13
信託の引受け	特定の者が一定の目的に従い財産の管理・処分その他の当該目的の達成のために必要な行為をするべきものとしてすること

③ 附属的商行為

附属的商行為とは、商人がその営業のためにする行為のことです。附属的商行為の具体例としては、営業資金に充てるためにお金を借りることなどが挙げられます。

なお、商人の行為は、その**営業のために**するものと推定されます（503条2項）。図 29-36-3

※8 具体例をイメージ

例えば、レンタル業などである。

※9 具体例をイメージ

例えば、クリーニング店などである。

※10 具体例をイメージ

例えば、旅館・ゴルフ場などである。

※11 具体例をイメージ

例えば、倉庫業者などである。

※12 具体例をイメージ

例えば、結婚相談所などである。

※13 具体例をイメージ

例えば、保険代理店などである。

2 商業登記

(1) 商業登記とは何か

商業登記とは、商人の営業に関する重要な事項を登記させることで、その登記を見た相手方が安心してその商人と取引をすることができるようにする制度のことです。**※1**

(2) 商業登記の効力

商業登記には、**一般的効力**と**不実登記の効力**という2つの効力があります。

【商業登記の効力】

一般的効力	登記すべき事項は、登記した後は、善意の第三者に対しても対抗することができる（9条1項前段） ※第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、第三者に対抗することはできない（9条1項後段） ※2 ※3
不実登記の効力	故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない（9条2項）

※1 具体例をイメージ

例えば、未成年者が営業を行うときは、その登記をしなければならないとされている（5条）。

※2 参考

正当な事由とは、災害による交通断絶や登記簿の滅失等により登記事項を知ることができないという客観的障害に限られ、長期旅行・病気等の主観的事情は含まれない。

※3 引っかけ注意!



「対抗することができない」とは、当事者から善意の第三者に対して主張できないという意味ですから、善意の第三者から当事者に対して主張することは、9条1項と関係なく認められます。

※4 具体例をイメージ

例えば、「〇〇商店」などである。

3 商号

(1) 商号とは何か

商号とは、商人がその営業上自己を表すために用いる名称のことです。**※4**

商号はその商人を表す名称ですから、**文字**で記載することができ、かつ、**呼称**できるものでなければなりません。したがって、記号や図形を商号とすることはできません。

(2) 商号の個数

① 会社の商号

会社の商号は、会社の人格を表す名称ですから、会社が複数の営業を行う場合であっても、その商号は**1個**に限られます。

② 個人商人の商号

個人商人の場合、数個の営業を営むときには、**各営業につきそれぞれ別個の商号**を使用することができます。

ただし、1個の営業につき、商号は1個に限られます（これ

を**商号単一の原則**といいます)。1個の営業につき数個の商号の使用を認めると、営業の同一性につき誤認されるおそれがあるからです。

(3) 商号の選定

商人は、原則として、商号を自由に選ぶことができます（これを**商号選定自由の原則**といいます）。しかし、例外的に、以下のような制限があります。

【商号選定の制限】

営業の主体を誤認させる商号選定の禁止	不正の目的をもって、他の商人であると誤認させるおそれのある名称又は商号を用いてはならない（12条1項）
会社の商号に関する制限	①会社は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の種類に従い、それぞれの商号中に株式会社・合名会社・合資会社・合同会社という文字を用いなければならない（会社法6条2項） ②会社は、他の種類の会社であると誤認させるおそれのある文字を用いてはならない（会社法6条3項）
個人商人の商号に関する制限	会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認させるおそれのある名称又は商号を使用してはならない（会社法7条）

(4) 商号の不正使用に対する措置

不正の目的をもって他の商人であると誤認させる商号の使用によって利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、**侵害の停止又は予防**を請求することができます（12条2項）。※5

(5) ^{ないたがし}名板貸

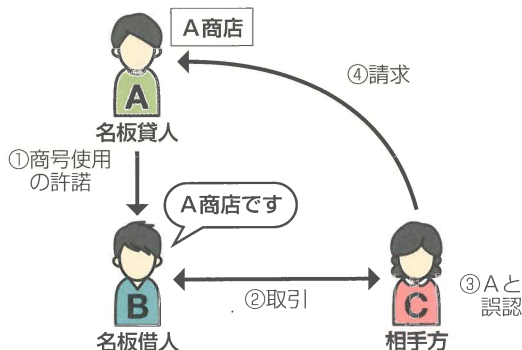
① 名板貸とは何か ㊦ 23-36

事例

商人Aが、商人Bに対してAの商号をもって営業を行うことを許諾したところ、Aの商号を使用したBと取引をした相手方Cは、当該取引を自己とAとの取引であると誤認した。

※5 参考

自らの商号について登記していなくても、侵害の停止又は予防を請求することができる。



上の事例の場合、契約は実際に取引をしたBとCの間で成立しますから、CはBに対してのみ取引によって生じた債務の弁済を請求できるのが原則です。

しかし、BがAの商号を使用したため、Cは自己とAとの取引であると誤認しているわけですから、CからすればAに対しても債務の弁済を請求したいところでしょう。

そこで、自己の商号を使用して営業を行うことを他人（**名板借人・B**）に許諾した商人（**名板貸人・A**）は、自己が営業を行うものと誤認して当該他人と取引した者（相手方・C）に対し、当該他人と**連帯して**、その取引によって生じた債務を弁済する責任を負わなければなりません（14条）。これは、名板貸人を営業主と信じて取引関係に入った相手方を保護するものです。

② 名板貸人の責任の要件

名板貸人の責任が発生するための要件は、以下の3つです。

【名板貸人の責任の要件】

1	名板借人が名板貸人の商号を使用して営業を行うこと ※1
2	名板貸人が名板借人に対して商号の使用を許諾すること
3	相手方が名板貸人を営業主であると誤認すること ※2

③ 名板貸人の責任の範囲

名板貸人が名板借人と連帯して責任を負う債務は、「**取引によって生じた債務**」です。これには、取引によって直接生じた債務のほか、その不履行による損害賠償債務等の本来の債務が

※1 重要判例

営業が同種であるからこそ営業主体の誤認が生じうるため、名板貸人の責任が成立するためには、特段の事情のない限り、名板貸人の営業と名板借人の営業が同種であることが必要である（最判昭43.6.13）。

※2 重要判例

「誤認」とは、相手方の善意無重過失を意味する（最判昭41.1.27）。

変形したものも含まれます。※3 ※4

(6) 商号の譲渡

商人の商号は、**営業とともにする場合又は営業を廃止する場合**に限り、譲渡することができます（15条1項）。

商号が営業上の名称として社会的・経済的に信用を集める機能を有するものであることから、商号を営業と切り離して個別に譲渡することは認められていません。

4 営業譲渡

(1) 営業譲渡とは何か

営業譲渡とは、①一定の営業目的により組織化され有機的一体として機能する財産の譲渡であって、②譲受人が営業活動を承継し、③譲渡人が法律上当然に**競業禁止義務**※5を負うこととなるもののことです（最大判昭40.9.22）。「**有機的一体として機能する財産**」というのは聞きなれない言葉かもしれませんが、要するに得意先関係やノウハウも含めて譲渡されるということです（単なる財産の譲渡ではありません）。

(2) 譲渡人の競業禁止義務

譲渡人が同種の営業を再開できるとすると、得意先関係やノウハウを譲渡した意味がなくなってしまうことから、譲渡人に競業禁止義務が課せられています。

【譲渡人の競業禁止義務】

原則	譲渡人は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市区町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から 20年間 は、同一の営業を行ってはならない（16条1項） 圖21-39-ウ
特約がある場合	譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から 30年 の期間内に限り、その効力を有する（16条2項）
不正の競争の目的がある場合	譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない（16条3項）※6

※3 重要判例

名板借人の詐欺的行為のような取引行為の外形をもつ不法行為（取引的不法行為）に基づく損害賠償債務は、「取引によって生じた債務」に当たる（最判昭58.1.25）。

※4 重要判例

名板借人による交通事故のような事実的不法行為に基づく損害賠償債務は、「取引によって生じた債務」に当たらない（最判昭52.12.23）。

※5 用語

競業禁止義務：同一の営業を行ってはならないという義務のこと。

※6 引っかけ注意!



不正の競争の目的をもって同一の事業を行うことは、地域・期間に関係なく禁止されます。

(3) 譲受人の責任

① 商号の続用あり

譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合、譲受人は、原則として、**譲渡人の営業によって生じた債務**を弁済する責任を負います（17条1項）。※1 図21-39-イ

もっとも、譲受後、遅滞なく、譲受人がその本店の所在地において譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の**登記**をした場合や、譲受人及び譲渡人から第三者に対してその旨の**通知**をした場合には、責任を負いません（17条2項）。

② 商号の続用なし

譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合、譲受人は、原則として、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負いません。

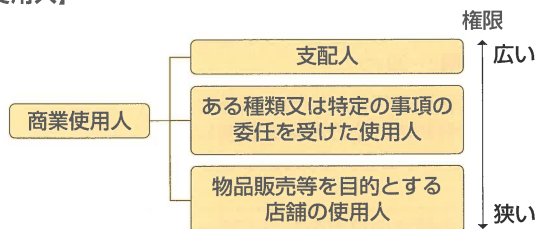
もっとも、譲渡人の事業によって生じた債務を引き受ける旨の**広告**をしたときは、譲受人は、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負います（18条1項）。

5 商業使用人

商業使用人とは、雇用契約によって特定の商人に従属し、その業務を補助する人のことです。

商業使用人は、その権限の広い順に、①**支配人**、②**ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人**、③**物品販売等を目的とする店舗の使用人**に分類されます。※2

【商業使用人】



※1 参考

譲渡人は債務を弁済する責任を免れるわけではなく、譲渡人と譲受人の連帯債務となる。図21-39-イ

※2 具体例をイメージ

①支配人の例としては支店長が、②ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人の例としては部長・課長が、③物品販売等を目的とする店舗の使用人の例としては店員が、それぞれ挙げられる。

(1) 支配人

① 支配人とは何か

支配人とは、商人の営業所の営業の主任者として選任された者のことです。 図26-36-2

② 支配人の権限

支配人は、以下のような権限を有しています。

【支配人の権限】

包括的代理権	支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する（21条1項） 図18-36-ア ※3 ※支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない（21条3項） 図18-36-ア、26-36-3
使用人の選任・解任権	支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる（21条2項） 図26-36-2

③ 支配人の義務

支配人は、雇用及び委任の規定に基づき、善管注意義務（民法644条）、報告義務（民法645条）等の一般的義務を負います。

また、支配人は、商人の許可を受けなければ、以下の行為をすることができません（23条1項）。これを**競業避止義務**（2）、**精力分散防止義務**（1、3、4）といいます。

【商人の許可を要する支配人の行為】

1	自ら営業を行うこと 図18-36-イ ※4
2	自己又は第三者のために商人の営業の部類に属する取引をすること 図18-36-イ
3	他の商人・会社・外国会社 ※5 の使用人となること 図26-36-4
4	会社の取締役・執行役・業務執行社員となること

④ 表見支配人

表見支配人とは、商人の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人のことです。

表見支配人は、当該営業所の営業に関し、一切の**裁判外**の行為をする権限を有するものとみなされますが、相手方が**悪意**であったときは、この限りではありません。 図18-36-ウ、26-36-5 ※6

※3 過去問チェック

支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有し、支配人の代理権に加えた制限は、それを登記した場合に、善意の第三者に対抗することができる。→×（18-36-ア）

※4 過去問チェック

支配人は、商人の許可を受けなければ自ら営業を行うことができないが、商人の許可を受けなくとも自己または第三者のために商人の営業の部類に属する取引を行うことができる。→×（18-36-イ）

※5 用語

外国会社：外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するもの（会社法2条2号）。

※6 過去問チェック

商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、支配人として選任されていなくても、当該営業所の営業に関しては、**支配人**とみなされる。→×（26-36-5）

(2) ある種類・特定事項の委任を受けた使用人

商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項について、一切の**裁判外**の行為をする権限を有します（25条1項）。そして、この代理権に加えた制限は、**善意の第三者**に対抗することができません（25条2項）。 18-36-エ

(3) 物品販売等を目的とする店舗の使用人

物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、相手方が**悪意**の場合を除き、その店舗にある物品の販売等をする権限を有するものとみなされます（26条）。 18-36-オ

6 代理商

(1) 代理商とは何か

代理商とは、商業使用人ではないものの、一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の代理又は媒介  1 をなす人のことをいいます（27条）。 2

代理商は、商業使用人のように本人に対して従属関係に立つことなく、**委任契約**に基づく独立の商人として代理又は媒介の委託を受ける者です。

(2) 代理商の義務

代理商は、商人の許可を受けなければ、以下の行為をすることができません（28条1項）。代理商の負う義務は、支配人が負う義務（23条）よりもその範囲が狭くなっていますが、これは、支配人が商人に従属すべき立場にあるのに対して、代理商は独立の商人だからです。

【商人の許可を要する代理商の行為】

1	自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること
2	その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役・執行役・業務執行社員となること

1 用語

媒介：当事者の間に立って、両者の間に商行為を成立させる手助けをすること。

2 参考

取引の代理をなす代理商のことを締約代理商、取引の媒介をなす代理商のことを媒介代理商という。

[商業使用人と代理商のまとめ]

	商業使用人	代理商
資格	自然人でなければならない	法人でもよい
商人との関係	雇用契約 (商人に従属する)	委任又は準委任契約 (商人から独立している)
代理権	授与しないこともできる	
競業避止義務	負う (23条 1 項 2 号)	負う (28条 1 項 1 号・2 号)
精力分散防止義務	負う (23条 1 項 1 号・3 号・4 号)	負わない

確認テスト

- ☐☐☐ 1 登記すべき事項は、登記した後は、善意の第三者に対しても対抗することができる。
- ☐☐☐ 2 自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、自己が営業を行うものと誤認して当該他人と取引した者に対し、当該他人と折半で、その取引によって生じた債務を弁済する責任を負わなければならない。
- ☐☐☐ 3 営業譲渡における譲渡人は、譲受人と同一の市区町村の区域内において、同一の営業を行うことができる。
- ☐☐☐ 4 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

解答 1 ○ (9条 1 項前段) 2 × 折半ではなく、連帯して責任を負わなければならない (14条)。 3 × 営業譲渡における譲渡人は競業避止義務を負う (16条 1 項)。 4 ○ (21条 1 項)

学習のPOINT



ここでは、商行為に適用されるルールについて学習していきます。民法の条文を修正したものがほとんどなので、民法の条文を確認しながら学習するとよいでしょう。

1 商行為の特則

商行為については、営利主義、取引の安全・迅速が強く要請されることから、一般市民の間の取引について定めた民法とは異なる特則が定められています。

具体的には、以下のような違いがあります。

(1) 商行為の代理と委任

① 代理の方式

商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、**本人**に対してその効力を生じます(504条本文)。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、**代理人**に対して履行の請求をすることを妨げないとされています(504条ただし書)。**※1**

過元-36

民法では、代理人が本人のためにすることを示すこと(顕名)が必要とされています(民法99条1項)。しかし、代理人がその都度顕名をすることは手間がかかり、また、相手方も本人のためになされたことを知っていることが多いため、商行為の代理については顕名が不要とされています。

② 商行為の委任

商行為の受任者は、**委任の本旨**に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができます(505条)。

受任者は、委任の本旨に従い善管注意義務を負っていますので(民法644条)、本人の利益のために幅広い活動を行うことができます。したがって、この規定は、民法上の善管注意義務の

※1 重要判例

商法の規定によれば、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行を請求することができるかとされているが(504条ただし書)、判例は、相手方保護のため、相手方は、その選択により、本人との法律関係または代理人との法律関係のいずれかを主張できるとしている(最大判昭43.4.24)。**過元-36-3・5**

規定を明確化した規定にすぎないと考えられています。

③ 代理権の消滅

商行為の委任による代理権は、**本人の死亡**によっては、消滅しません（506条）。30-36-ア

民法では、本人の死亡により代理権も消滅します（民法111条1項1号）。しかし、商行為の代理においては、取引の安全を図る必要性が高いため、商行為の委任による代理権は存続する（本人の相続人との間に代理関係が存続する）ものとされています。

(2) 契約の成立

① 隔地者間における契約の申込み

商人である隔地者の間において承諾の期間を定めずに契約の申込みを受けた者が**相当の期間**内に**承諾の通知**を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失います（508条1項）。

25-36-イ

民法では、本条所定の場合には、相当期間経過後、契約の申込みを撤回し得るにとどまり（民法525条）、撤回されるまで申込みの効力は消滅しません。しかし、商法は、商取引の迅速性の見地から、申込みの効力を長く継続させて申込者の自由を拘束するべきではないとして、申込みは当然に失効するものとされています。

② 諾否の通知義務

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する**諾否の通知**を発しなければなりません（509条1項）。そして、商人がこの通知を発することを怠ったときは、その商人は、契約の申込みを承諾したものとみなされます（509条2項）。25-36-ウ

民法では、遅滞なく諾否の通知を発する義務はなく、承諾の意思表示がなければ契約は成立しません（民法522条1項）。しかし、商法では、平常取引をする者の間には継続的な取引関係があり、商取引の迅速性を図る必要があることから、承諾者の沈黙を承諾とみなして契約が成立するようにしています。

③ 受領物保管義務

商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、**申込者の費用**をもってその物品を保管しなければなりません（510条本文）。ただし、その**物品の価額がその費用を償うのに足りないとき**、又は商人がその**保管によって損害を受けるとき**は、この限りではありません（510条ただし書）。 18-37-ア  1

商取引では、契約の申込みと同時に、見本又は承諾を預期しての目的物の送付が行われることがあることから、物品の安全を確保するとともに商人に対する信用を保護するため、受領物保管義務が設けられています。

(3) 報酬請求権

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、**相当な報酬**を請求することができます（512条）。 18-37-ウ  2、30-36-イ

民法上の委任契約では、無報酬が原則とされています（民法648条1項）。しかし、商人は営利目的で行動するのが通常ですから、商人の場合は、当然に報酬を請求できるものとしています。

(4) 商事債権の性質

① 金銭消費貸借の利息請求権

商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、**法定利息**を請求することができます（513条1項）。

民法では、特約がない限り、消費貸借は無償です（民法589条1項）。しかし、商人である貸主は、営利を目的として活動していますから、当然に法定利息を請求できるものとされています。

② 債務の履行場所

商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しは**その行為の時にその物が存在した場所**において、その他の債務の履行は**債権者の現在の営業所**（営業所がない場合

1 過去問チェック

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受け、申込みとともに受け取った物品がある場合において、その申込みを拒絶するときは、相当の期間内にその物品を相手方の費用により返還しなければならない。→  ×
(18-37-ア)

2 過去問チェック

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をした場合は、報酬に関する契約がなくとも、相当な報酬を請求することができる。→  ○
(18-37-ウ)

にあっては、その住所)において、それぞれしなければなりません(516条)。

民法では、特定物の引渡債務以外の債務の履行場所は、債権者の現在の住所です(民法484条1項)。しかし、商行為における債権者は商人であることが多いので、営業所※3を住所に優先させています。

(5) 商事債権の担保

① 多数債務者の連帯

数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。図18-37-イ※4、30-36-ウ

民法では分割債務が原則ですが(民法427条)、商法では、債務の履行を確実にするために、連帯債務が原則とされています。

② 連帯保証

保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担します(511条2項)。図30-36-工

民法では、保証人は、連帯保証とする旨の意思表示をしない限り、催告・検索の抗弁権(民法452条、453条)、分別の利益(民法456条)を有します。しかし、商法では、債務の履行を確実にするために、保証人の責任を強化し、連帯保証が原則とされています。

③ 流質契約※5の自由

民法349条では弁済期前の流質契約が禁止されていますが、**商行為によって生じた債権**を担保するために設定した質権については、弁済期前の流質契約も許されます(515条)。これは、商行為における金融を容易にするため認められたものです。図18-37-オ※6

④ 商人間の留置権

商人間においてその双方のために商行為となる行為によって

※3 用語

営業所：商人の営業上の活動の中心となる一定の場所のこと。この営業所には、本店と支店がある。

※4 過去問チェック

数人がその一人または全員のために商行為である行為によって債務を負担した場合は、その債務は各自が連帯して負担する。→○(18-37-イ)

※5 用語

流質契約：被担保債権が弁済されない場合に、質権者に質物の所有権の取得を認める契約のこと。

※6 過去問チェック

商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを契約で定めることができる。→○(18-37-オ)

生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、当事者の別段の意思表示があるときを除き、その債権の弁済を受けるまで、その**債務者との間における商行為**によって自己の占有に属した**債務者の所有する物又は有価証券**を留置することができます(521条)。18-37-エ 1、24-36

商人間の取引は継続的であることが通常であるため、民法で要求される被担保債権と留置物との牽連性(※P432参照)は、不要とされています。

【商行為の特則のまとめ】 2

	民法	商法
代理の方式	顕名が必要(99条1項)	顕名は不要(504条)
本人の死亡と代理権	消滅する(111条1項1号)	存続する(506条)
多数当事者の債務	分割債務(427条)	連帯債務(511条1項)
保証債務	通常の保証(446条)	連帯保証(511条2項)
流質契約	禁止(349条)	許容(515条)
留置権	①目的物が債務者の所有物であることは不要 ②目的物と債権の牽連性は必要(295条1項本文)	①目的物が債務者の所有物であることが必要(521条) ②目的物と債権の牽連性は不要

2 商人間の売買契約

商人間の売買契約については、取引の安全・売主の保護という観点から、民法の売買契約に関する規定とは異なる特則が定められています。

(1) 売主による目的物の供託・競売

民法では、買主が売買の目的物を引き取ってくれない場合、売主は、その目的物を供託することができます(民法494条1項1号)。また、売買の目的物が供託に適さない場合、裁判所の許可を得て、競売することができます(民法497条)。

しかし、裁判所の許可には時間がかかり、売主にとって不利となります。そこで、商人間の売買においては、供託のみなら

※1 過去問チェック

当事者の一方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、債権の弁済を受けるまで、債権者が占有する債務者所有の物または有価証券を留置することができる。
→X (18-37-エ)

※2 法改正情報

民法大改正に伴い、商事消滅時効(522条本文)は廃止され、民法と統一された(民法166条)。また、商事法定利率(514条)も廃止され、民法と統一された(民法404条)。

※3 過去問チェック

A株式会社は、輸入業者Bとの間でバナナの売買契約を締結した。履行期日になったが、Aの加工工場でストライキが起こり、Aは期日にバナナを受領することができなかった。そこでBは、Aへの催告なしに、そのバナナを競売に付し、競売の代金をバナナの代金に充当したが、これについて、Bに責任はない。→O (21-36-4)

ず**競売**もすることができるものとされ、競売の際に相当の期間を定めて催告をすれば、裁判所の許可を得る必要はありません(524条1項前段)。

また、損傷その他の事由による**価格の低落**のおそれがある物は、催告をしないで競売に付することができます(524条2項)。21-36-4 ※3

そして、売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その**代価を供託**しなければなりません、その代価の全部又は一部を**代金に充当**することを妨げないとされています(524条3項)。21-36-4 ※3

(2) 定期売買の履行遅滞による解除

民法では、定期売買の時期を経過したため契約を解除する場合には、相手方に対して解除の意思表示をしなければなりません(民法540条1項、542条1項4号)。

しかし、解除の意思表示を必要とすると、解除の意思表示がされるまで売主は不安定な地位に置かれることになります。そこで、商人間の売買においては、相手方が直ちに**履行の請求**をしない限り、当然に**契約を解除**したものとみなすこととして、解除の意思表示を不要としています(525条)。21-36-5 ※4

(3) 買主による目的物の検査・通知

民法上の売買契約においては、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合(契約内容不適合)、買主は、売主の担保責任を追及することができます(民法562条1項)。

これに対して、商人間の売買契約においては、契約内容不適合があっても、受け取った目的物を**遅滞なく検査**し、契約内容不適合を発見した場合には**直ちに売主に対して通知**をしなければ、売主の担保責任を追及することができません(526条1項、2項前段)。これは、売主が不安定な立場に置かれることを防止して、売主を保護するためです。※5 21-36-1・2 ※6

(4) 買主による目的物の保管・供託

民法では、売買の目的物に契約内容不適合が存在したため契約が解除されたとしても、買主は、その目的物の返還義務を負

※4 過去問チェック

A株式会社は、輸入業者Bとの間でクリスマス商品の売買契約を締結したが、輸出国の工場での製造工程にトラブルが生じ、商品の製造が遅れたため、納入がクリスマスに間に合わなかった。Aが、Bに対して契約の解除等何らの意向を示さずに、Bからの度重なる連絡を無視し続けた場合、クリスマス商品の受領を拒むことはできない。→
× (21-36-5)

※5 重要判例

526条は、不特定物売買についても適用される(最判昭35.12.2)。

※6 過去問チェック

A株式会社は、輸入業者Bとの間でコーヒー豆の売買契約を締結した。Aの仕入れ担当者はコーヒー豆の納入に立ち会い、数量の確認および品質の検査を行った。その際、コーヒー豆の品質の劣化を認識していたが、Bに直ちには通知しなかった。この場合に、AはBに対して売買契約の解除、代金の減額または損害賠償を請求することができない。→○
(21-36-2)

うにすぎず（民法545条1項本文）、目的物を保管・供託する義務はありません。

しかし、買主が目的物を適切に保管等しないと、売主は転売の機会を失ってしまいます。そこで、商人間の売買においては、売買の目的物に契約内容不適合が存在したため契約が解除された場合でも、買主は、**売主の費用**で、売買の目的物を**保管・供託**しなければなりません（527条）。また、**品違いや数量超過分**についても同様とされます（528条）。

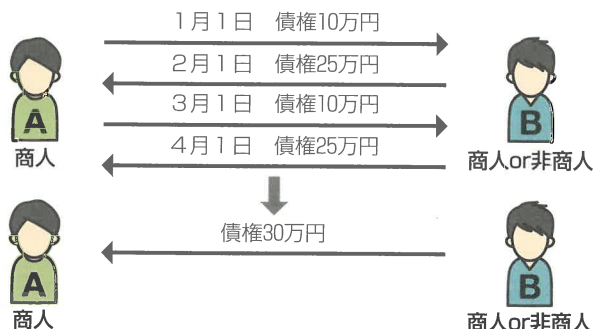
ただし、売主及び買主の営業所（営業所がない場合にあっては、その住所）が**同一の市町村**の区域内にある場合には、保管・供託する義務はありません（527条4項）。21-36-3 

3 交互計算契約

交互計算契約とは、商人間又は商人と商人でない人の間で平常取引をする場合（普段から継続的に取引をする場合）に、一定の期間内の取引から生ずる債権・債務の総額について相殺をし、その残額の支払いをする契約のことで（529条）。

例えば、以下のような場合に、AとBの間に1月1日～4月1日の取引から生ずる債権・債務の総額について相殺をし、AがBに対して30万円を支払う旨の契約などです。

【交互計算】



民法上の相殺は、対立する2つの債権を対当額において消滅させるものです。もっとも、普段から継続的に取引をする者の間では、対立する2つの債権・債務が発生するたびに相殺をし

※1 過去問チェック

A株式会社は、輸入業者Bとの間でチューリップの球根の売買契約を締結した。Aの仕入れ担当者が引渡しに立ち会ったところ、球根の種類が予定していたものと異なっていた。そこで、Aは直ちに売買契約の解除をBに通知した。Bの営業所が同一市内にあったため、Bが引き取りに来るまでの間、Aは球根を放置していたところ、発芽し、売り物には適さないものになったが、Aには責任はない。→○（21-36-3）

て残額を支払うのではなく、一定期間内に発生する債権・債務を一まとめにして相殺をした方が、お金のやり取りに伴う危険と手数を省略することができます。そこで、民法における相殺の特則として、交互計算契約という制度が設けられています。

4 とくめいくみあい 匿名組合契約

(1) 匿名組合契約とは何か

匿名組合契約とは、当事者の一方が相手方のために出資をし、相手方がその営業から生ずる利益を分配することを約束する契約のことです（535条）。これは、資金はもっているが自分で経営をする意思や能力がない一般市民と、経営能力はあるが資金の乏しい商人を結びつける制度です。

なお、出資をした人を匿名組合員といい、営業を行う人を営業者といいます。匿名組合契約の関係をまとめると、以下の図のようになります。

【匿名組合契約】



(2) 匿名組合員の出資

匿名組合員の出資は、**営業者**の財産に属します（536条1項）。図20-40-2

また、匿名組合員は、**金銭その他の財産のみ**をその出資の目的とすることができます（536条2項）。図20-40-1

(3) 匿名組合員の権利・義務

① 業務執行権・代表権の不存在

匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができません（536条3項）。図20-40-4

② 第三者に対する権利・義務

匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利・義務を有しないのが原則です（536条4項）。

しかし、匿名組合員が営業者の商号中に自己の氏・氏名・商

号を使用することを許諾した場合は、その使用以後に生じた債務については、第三者に対して**連帯責任**を負うことになります(537条)。 20-40-3 ※1

(4) 匿名組合契約の終了

① 終了原因

匿名組合契約は、**解除**(540条)によって終了するほか、以下の事由によって終了します(541条)。

【匿名組合契約の終了原因】

	死亡	後見開始の審判	破産手続開始の決定
営業者	○	○	○
匿名組合員	×	×	○

○：終了する、×：終了しない

② 終了の効果

匿名組合契約が終了した場合、営業者は、匿名組合員にその**出資の価額**を返還しなければなりません、出資が損失によって減少したときは、その**残額**を返還すれば足ります(542条)。

20-40-5 ※2

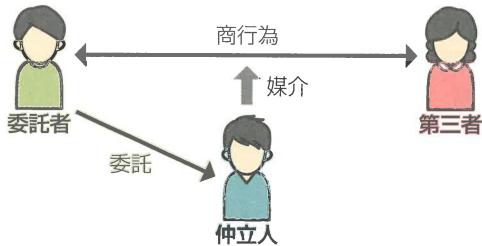
5 なかだちにん といや
仲立人・問屋

(1) 仲立人

仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者のことです(543条)。 ※3

仲立人は、当事者の間に立って商行為の成立に尽力する者であり、自ら契約当事者又は当事者の代理人となって契約を締結するわけではありません。

【仲立人】



※1 過去問チェック

匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利および義務を有しないが、匿名組合員が自己の商号などを営業者の商号として使用することを許諾したときには、その使用以後に生じた債務について、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。→ ○ (20-40-3)

※2 過去問チェック

匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員に対してその出資の価額を返還しなければならず、出資が損失によって減少した場合には、営業者は、その減少額をてん補して匿名組合員に出資の価額を返還する義務を負う。→ × (20-40-5)

※3 具体例をイメージ

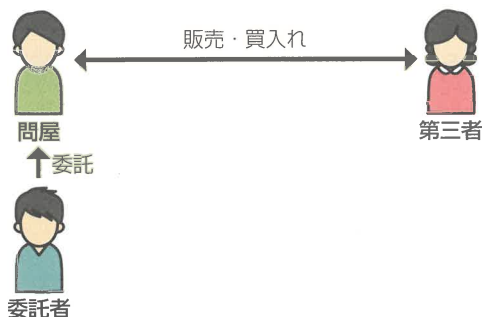
例えば、商人ではない者を相手に旅館等をあつせんし宿泊契約の締結を媒介する業者などである。

(2) 問屋

問屋とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者のことです (551条)。※4

問屋は、仲立人と異なり、委託者のために自ら契約当事者となってその行為から生ずる権利を有し、また、義務を負うこととなります (552条1項)。

【問屋】



6 運送営業

運送営業とは、物や人を場所的に移動することを内容とする営業のことです。このうち、物を対象とする場合を**物品運送**、人を対象とする場合を**旅客運送**といいます。※5

(1) 物品運送

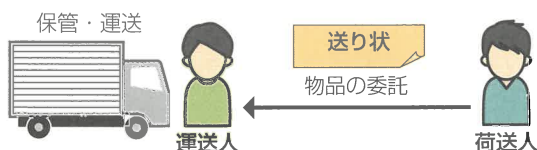
① 物品運送とは何か

物品運送とは、運送人が荷送人 (運送委託者) から委託を受けた物品を保管しつつ、その物品を運送するものです。

② 送り状

荷送人は、運送人の請求によって**送り状**を交付しなければなりません (571条1項)。これは、運送品や到達地など運送契約の内容を運送人に知らせるためです。図22-40-ア

【物品運送】



※4 具体例をイメージ

例えば、証券会社などである。

※5 具体例をイメージ

物品運送の例としては宅配業が、旅客運送の例としては観光バス業が挙げられる。

③ 運送賃

運送品がその性質または瑕疵によって滅失・損傷したときでも、荷送人は、**運送賃**の支払を拒むことができません（573条2項）。 22-40-ウ

④ 運送人の損害賠償責任

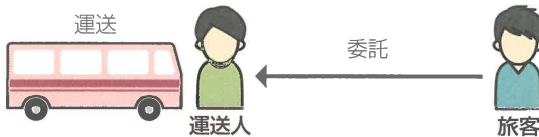
運送人は、運送品の受取り・運送・保管・引渡しについて注意を怠らなかったことを証明しない限り、運送品の滅失・損傷（その原因が生じたことを含む）、延着について**損害賠償責任**を免れることはできません（575条）。 1  22-40-工、27-36-1

(2) 旅客運送

① 旅客運送とは何か

旅客運送とは、運送人が旅客から委託を受けてその旅客を運送するものです。

【旅客運送】



② 運送人の損害賠償責任

旅客運送の運送人は、以下のような損害賠償責任を負います。

【旅客運送の運送人の損害賠償責任】

旅客の損害		運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、損害賠償責任を負う（590条）
手荷物の損害	託送手荷物	旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃の請求の有無にかかわらず、物品運送の運送人と同一の責任を負う（592条1項）
	携帯手荷物	旅客から手荷物の引渡しを受けない場合、その滅失・損傷については、故意又は過失がない限り、損害賠償責任を負わない（593条1項）

1 参考

貨幣・有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するにあたりその種類及び価額を通知したときでなければ、運送人は損害賠償責任を負わない（577条1項）。 27-36-2、2-36-イ

7 じょうおくえいぎょう 場屋営業

(1) 場屋営業とは何か

場屋営業とは、一般市民が集まるのに適した設備を設け、これを利用させることを内容とする営業のことです。※2

(2) 商事寄託

商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善管注意義務を負います(595条)。図19-40-1 ※3、30-36-才

(3) 場屋営業者の責任 ※4

場屋営業においては多数の客が出入りしてその設備を利用するため、客の携帯品について盗難や紛失が生じる危険が大きいことから、場屋営業者の責任が強化されています。

例えば、場屋営業者は、客から寄託を受けた物品の滅失・損傷については、不可抗力によるものであることを証明しない限り、損害賠償責任を免れることができません(596条1項)。図19-40-2、27-36-3

また、客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失・損傷したときは、損害賠償責任を負います(596条2項)。図19-40-4、27-36-4

さらに、客が場屋の中に携帯した物品について責任を負わない旨を表示した場合でも、場屋営業者は、これらの責任を免れることができません(596条3項)。図19-40-5 ※5

※2 具体例をイメージ

例えば、旅館やゴルフ場などである。

※3 過去問チェック

商人がその営業の範囲内において物品の寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもってその物品を保管する義務を負う。

→○(19-40-1)

※4 参考

貨幣・有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知して寄託したのでない限り、その滅失・損傷について場屋営業者は損害賠償責任を負わない(597条)。図19-40-3、27-36-5

※5 過去問チェック

客が携帯する物品について責任を負わない旨を告示した場合には、場屋営業者は、損害賠償の責任を負うことはない。

→×(19-40-5改)

確認テスト

- ☐☐☐ 1 数人の者が、その1人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
- ☐☐☐ 2 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
- ☐☐☐ 3 匿名組合員は、金銭その他の財産のみならず、信用及び労務をその出資の目的とすることができる。
- ☐☐☐ 4 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合において、報酬を受けないときは、自己の物に対するのと同じ注意義務を負う。

解答

- 1 ○ (511条1項) 2 ○ (526条1項) 3 × 金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる (536条2項)。 4 × 報酬を受けないときであっても、善管注意義務を負う (595条)。

第2章 会社法

第1節 会社法総論

重要度 C



学習のPOINT

ここでは、会社法全体に共通するルールについて学習します。直接出題されることはほとんどありませんが、以降の学習の前提となるところなので、一通りは理解しておいてください。

1 会社とは何か

商人は利益の追求のために行動する者ですが、大きな利益を上げるためには、営業の規模を広げていく必要があります。また、営業のための資金も自分で用意するのは限界がありますから、他人から資金を集めることが必要となってきます。

このような必要性を満たすために編み出された手法が会社というものです。つまり、会社という組織を作ることにより、営業の規模を広げ、資金集めをすることができるようになります。

2 会社の特質

会社の特質は、①**営利性**、②**社団性**、③**法人性**の3つです。

(1) 営利性

営利性とは、対外的な活動によって利益を得て、その利益を社員^{※1}に分配することです。要するに、お金儲けのことです。

(2) 社団性

社団とは、共通の目的を有している複数人の結合体のことです。もっとも、会社法は、社員が1人しかいない**一人会社**を許容しています。

※1 用語

社員：出資者（会社のオーナー）のこと。日常用語における「社員」のように、従業員という意味ではない。

(3) 法人性

会社は**法人**であり（3条）、法人格の付与により**権利能力**を取得する（権利を有し義務を負う）ことになります。

もっとも、会社の権利能力は、以下のような制限を受けます。

【会社の権利能力の制限】

性質による制限	会社は、法人という性質上、生命・身体に関する権利義務を有しない
法令による制限	会社のような法人は政策上認められたものにすぎないため、会社の権利能力は法令による制限を受ける
目的による制限	会社の権利能力は、定款※1 所定の目的の範囲内でのみ認められる（民法34条）

3 会社の種類

(1) 株式会社と持分会社

会社には、個性が重視されない多数の人が大規模な事業を行うことを想定した**株式会社**と、相互に信頼関係を有する少数の人が小規模な事業を行うことを想定した**持分会社**があります。

そして、持分会社は、社員が会社の債務について無限責任※2を負うか有限責任※3を負うかによって、①**合名会社**、②**合資会社**、③**合同会社**の3種類に分けることができます。

【持分会社】

合名会社	社員全員が 無限責任 を負う会社（576条2項）※4
合資会社	無限責任 を負う社員と 有限責任 を負う社員とが併存する会社（576条3項）
合同会社	社員全員が 有限責任 を負う会社（576条4項）

株式会社と持分会社についてまとめると、以下の図のようになります。

※1 用語

定款：会社内部の基本的なルールのこと。

※2 用語

無限責任：会社の債務について、社員が自分の財産で全額を弁済する責任を負うこと。

※3 用語

有限責任：会社の債務について、社員が出資額を限度として弁済する責任を負うこと。

※4 参考

無限責任社員は、①会社の財産をもってその債務を完済することができない場合、②会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合（社員が、会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く）には、連帯して、会社の債務を弁済する責任を負う（580条1項）。18-40-2

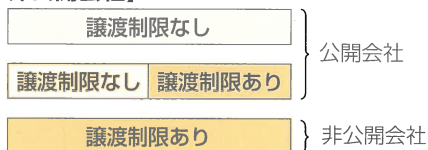
【株式会社と持分会社】



(2) 公開会社と非公開会社

発行する株式の全部が譲渡制限株式である場合を**非公開会社**、それ以外の場合を**公開会社**といます（2条5号）。 2-40-1

【公開会社と非公開会社】

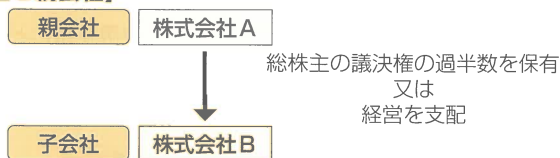


(3) 子会社と親会社

子会社とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもののことです（2条3号）。

他方、**親会社**とは、株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるもののことです（2条4号）。

【子会社と親会社】



4 株式会社の特質

株式会社については、大規模な事業を可能にするために、より多くの人が出資 5 できるような工夫がなされています。それが**株式**と**間接有限責任**です。

(1) 株式

株式とは、株式会社の出資者たる地位（株主といいます）を

※5 用語

出資：資金を提供すること。

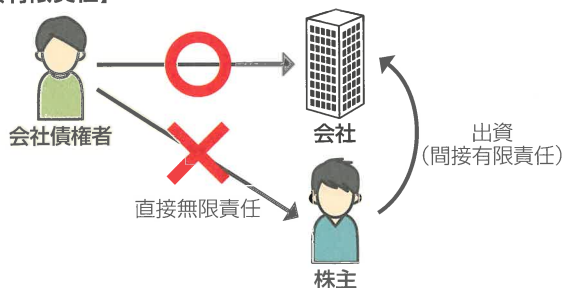
細分化して割合的単位の形にしたものです。※1

このように、出資者たる地位を細分化することにより、手持ちの資金があまりない人でも出資することができます。また、割合的単位の形にすることにより、株主の個性がなくなり、法律関係を単純化することができます。

(2) 間接有限責任

株主は、その有する**株式の引受価額**を限度として責任を負います（104条）。つまり、株主は、出資額以上に責任を負わされることがなく、また、会社債権者に対して直接債務を弁済する責任を負いません。これを**間接有限責任**といいます。■29-40-ア

【間接有限責任】



※1 具体例をイメージ

例えば、1億円の価値がある株式会社が100個の株式を発行した場合、1株の価値は100万円となり、半分である50個の株式をもっている人は、株式会社の半分（5000万円分）を所有していることになる。

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ 1 会社は法人であり、法人格の付与により権利能力を取得することになる。
- ☐ ☐ ☐ 2 合名会社とは、社員全員が有限責任を負う持分会社のことである。
- ☐ ☐ ☐ 3 株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。

解答 1 ○（3条） 2 × 合同会社である（576条4項）。 3 ○（間接有限責任：104条）



学習のPOINT

第2節～第5節では、株式会社に絞って解説していきます（持分会社については、第6節でまとめて解説します）。したがって、ここでは株式会社の設立について学習していきます。

1 設立の方法

(1) 発起人^{ほっきにん}

発起人とは、株式会社の設立を企画して、定款に署名又は記名押印した者のことです。

実際は会社設立の企画・事務を行った者であっても、定款に発起人として署名又は記名押印していなければ、法律上、発起人とは扱われません。^{※2}

(2) 設立の方法

株式会社を設立する方法には、以下の2種類があります。^{※3}

【株式会社の設立方法】

発起設立 (25条1項1号)	発起人が設立の際に発行する株式（設立時発行株式）のすべてを引き受け、会社成立後当初の株主となる設立方法
募集設立 (25条1項2号)	発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りにつき株式を引き受ける者を募集する設立方法 ^{※4}

2 設立手続

株式会社は、①定款^{ていかん}の作成→②株主の確定→③出資の履行→④設立時役員等の選任→⑤設立の登記といった手続を経て設立されます。

(1) 定款の作成

① 原始定款

株式会社の設立の第1段階として、発起人が定款を作成します（26条）。ここで作成される定款を**原始定款**といいます。

※2 参考

発起人の人数や資格に制限はなく、法人も発起人となることができる。

※3 参考

発起設立・募集設立のいずれの場合でも、発起人は、必ず1株以上引き受けなければならない（25条2項）。^図27-37-イ、2-37-ア

※4 参考

発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない（57条2項）。^図27-37-ア

原始定款は、**公証人の認証**を受けることによって、その効力を生じます（30条1項）。※1

② 定款に記載する事項

定款に記載する事項は、①**絶対的記載事項**、②**相対的記載事項**、③**任意的記載事項**の3種類に分類されます。

【定款記載事項】 図29-37-1

	意味	具体例
絶対的記載事項	必ず定款に定めなければならない事項であって、定めておかないと定款自体が無効となるもの	①目的 ②商号 ③本店の所在地 ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 図28-37-ア、元-37-ア ⑤発起人の氏名・名称・住所 ⑥発行可能株式総数 ※2 ※3
相対的記載事項	定款に定めがなくても定款自体の効力に影響はないものの、定めがない場合にはその効力が認められない事項	①変態設立事項（28条） ②株式の内容・種類株式の定め（107条、108条）
任意的記載事項	強行法規・公序良俗に反しなければ自由に定めることができる事項	①取締役の員数 ②定時株主総会の開催時期

③ 変態設立事項

変態設立事項とは、28条に規定されている4つの事項のことであり、会社の財産的基盤を危うくするおそれのある事項のことです。

変態設立事項には、以下の4種類があります。※4

【変態設立事項】

現物出資	金銭以外の財産による出資のこと ※5
財産引受	発起人が会社の成立を条件として成立後の会社のために一定の営業用の財産を譲り受ける契約のこと
発起人の報酬 その他の特別利益	発起人の労務に対して与えられる財産上の利益のこと
設立費用	会社の負担する設立に関する費用のこと ※6

※1 参考

会社成立後に定款を変更する場合は、公証人の認証は不要である。

※2 用語

発行可能株式総数：その株式会社が発行できる株式数のこと。

※3 参考

発起設立・募集設立のいずれの場合でも、発行可能株式総数を原始定款で定めていないときは、会社成立時までに定款を変更して定めなければならない（37条1項、98条）。図21-37-1、27-37-ウ

※4 参考

会社の設立に際して現物出資を行うことができるのは発起人のみであるが（34条1項、63条1項）、財産引受については、発起人以外の者もその相手方となることができる。図19-36-イ、24-37-ア、元-37-オ

※5 具体例をイメージ

例えば、不動産・動産・特許権などである。

※6 具体例をイメージ

例えば、設立事務所の賃借料や、設立事務をする事務員の給料などである。

変態設立事項については、①所定の事項を**原始定款**に記載し(28条)、②裁判所により選任される**検査役の調査**を受けなければなりません(33条1項)。

なお、**現物出資**と**財産引受**については、以下の場合に、②検査役の調査が不要とされます(33条10項)。

【検査役の調査が不要とされる場合】

1	定款に記載・記録された価額の総額が500万円を超えない場合
2	市場価格のある有価証券について定款に記載・記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
3	定款に記載・記録された価額が相当であることについて弁護士等の証明を受けた場合(現物出資財産等が不動産である場合、不動産鑑定士の鑑定評価も必要) 図2-37-ウ

(2) 株主の確定

① 株式の割当て

発起人は、株主を確定させるため、設立時発行株式に関する事項及び株主となる者(株式引受人)を決定します。これを**株式の割当て**といいます。

② 株式発行事項の決定

設立時発行株式に関する事項のうち、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額は、定款で定める必要がありますが(27条4号)、その他の事項は定款で定める必要はなく、原則として、**発起人の多数決**で決定することができます。^{※7}

ただし、①発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数、②①の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額、③成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項については、定款で定めていないときには、**発起人の全員の同意**を得て定めなければなりません(32条1項、58条1項・2項)。

(3) 出資の履行^{※8}

① 全額払込主義

発起人は、設立時発行株式の引受後遅滞なく、募集設立における募集株式の引受人は、発起人が定めた払込期日又は払込期間中に、引き受けた株式につき全額の払込み又は全部の給付

※7 参考

公開会社においては、会社設立時に発行する株式の数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない(37条3項)。図21-37-1、26-37-オ、2-40-2

※8 参考

発起人が出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない(50条2項)。図元-37-ウ

(出資の履行)をしなければなりません(34条1項本文、63条1項)。**※1** **※2** 図28-37-イ、元-37-イ

② 失権手続

発起人のうち出資を履行しない者がいる場合、発起人は、失権予告付で払込みを**催告**し、払込みがなければ**失権**することになります(36条1項・3項)。これに対して、発起人以外の引受人の不履行の場合、当然に**失権**することになります。図26-37-ウ、元-37-工

③ 払込取扱場所・払込取扱機関による保管証明

発起人の不正行為等(横領・詐取)を防止するため、払込みは、銀行・信託会社等の**払込取扱機関**の**払込取扱場所**においてしなければなりません(34条2項)。

そして、募集設立の場合には、発起人は、払込取扱機関に対して、払込金の**保管証明書**の交付を請求することができます(64条1項)。これに対して、発起設立の場合、保管証明制度は廃止されています。**※3** 図28-37-工、2-37-オ

④ 創立総会

創立総会とは、設立時株主によって構成され、設立中の会社の意思を決定するための機関のことです。

募集設立の場合、**発起人**は、設立時募集株式の払込期日又は払込期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、創立総会を招集しなければなりません(65条1項)。図19-36-ア、23-37-1

創立総会は、会社設立後の株主総会に相当するものであり、手続についても株主総会とほぼ同様となっています。

もっとも、創立総会の決議要件は、株主総会の決議要件とは異なり、原則として、議決権を行使できる設立時株主の議決権の**過半数**であって、出席した設立時株主の議決権の**3分の2以上**です(73条1項)。**※4** 図23-37-3

(4) 設立時役員等 **※5** の選任

① 選任方法

設立時役員等の選任方法は、発起設立と募集設立で異なります。

※1 参考

発起人全員の同意があるときは、登記・登録その他の権利の設定・移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができ(34条1項ただし書)。図28-37-イ、元-37-イ

※2 参考

株式の引受けに係る意思表示については、心裡留保(民法93条1項ただし書)と虚偽表示(民法94条1項)の規定は適用されない(51条1項、102条5項)。また、株式会社の成立後は、錯誤(民法95条1項柱書)・詐欺・強迫(民法96法1項)を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることもできない(51条2項、102条6項)。図26-37-イ

※3 参考

保管証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること、または当該金銭の返還に関して制限があることをもって、成立後の株式会社に対抗することはできない(64条2項)。図28-37-工

【設立時役員等の選任方法】 図29-37-5

発起設立	発起人が1株につき1個の議決権を有し、その議決権の過半数で選任する（40条1項、2項本文）
募集設立	創立総会の決議によって選任する（88条1項）

② 設立時取締役 ※6 の職務・権限等

設立時取締役が選任された後でも、設立事務を行うのは**発起人**です。図19-36-工 ※7、27-37-工

設立時取締役は、**設立事項**（現物出資等について定款記載価額が相当であるか、出資の履行が完了しているか、設立手続に法令や定款違反がないか等）の**調査**を行う権限のみを有します（46条1項、93条1項）。

そして、調査の結果、法令・定款違反等があれば、発起設立の場合は**各発起人に通知**し（46条2項）、募集設立の場合は**創立総会へ報告**しなければなりません（93条2項）。

③ 設立時役員等の解任

設立時役員等は、**会社が成立**するまでの間、解任することができます。設立時役員等の解任方法は、発起設立と募集設立で異なります。

【設立時役員等の解任方法】

発起設立	発起人の議決権の過半数（設立時監査等委員である設立時取締役又は設立時監査役を解任する場合は、3分の2以上の多数）によって解任する（43条1項）
募集設立	創立総会の決議によって解任する（91条）

(5) 設立の登記

株式会社は、その本店の所在地において**設立の登記**をすることによって成立します（49条）。

3 設立の瑕疵

(1) 設立無効

設立の登記が完了したとしても、設立手続に瑕疵があった場合には、設立は**無効**となります。※8

本来、無効であれば、いつでも誰でもその主張をすることができます。しかし、会社の設立の場合、すでに会社が成

※4 参考

創立総会においても、株主総会と同様、書面による議決権行使や電磁的方法による議決権行使が認められている（75条、76条）。図23-37-2

※5 用語

設立時役員等：会社の設立に際して、取締役、会計参与、監査役、会計監査人となる者のこと。

※6 用語

設立時取締役：株式会社の設立に際して取締役となる者のこと（38条1項）。

※7 過去問チェック

設立時取締役は、その選任の日から会社の設立の登記がなされるまでの期間において、発起人に代わって設立中の会社のすべての業務を行う権限を有する。→×

（19-36-工）

※8 具体例をイメージ

例えば、定款の絶対的記載事項を欠く場合や、公証人による定款認証がない場合などである。

立したものとして活動を開始し、多数の関係者が登場しています。そこで、設立無効は、**訴え**によってのみ主張することができます（828条1項柱書）。 2-37-イ

設立無効の訴えの提訴期間は**会社成立の日から2年以内**に限られ（828条1項1号）、提訴権者も株主・取締役・執行役・監査役・清算人に限定されています（828条2項1号）。

そして、設立無効判決により、会社の設立は、**将来に向かって**その効力を失います（839条）。

(2) 会社の不成立

会社の不成立とは、会社の設立が途中で挫折し、設立の登記に至らなかった場合のことです。

この場合、**発起人**は、連帯して、設立に関してした行為についてその責任を負い、設立に関して支出した費用を負担します（56条）。 19-36-オ  1、30-37-オ、2-37-エ

(3) 会社の不存在

会社の不存在とは、会社の設立手続の瑕疵が著しく、そのことが外観上も明らかな場合のことです。

この場合、誰でもいつでも会社の不存在を主張することができます。

4 設立関与者の責任

設立手続に関して違法・不正があった場合、発起人・設立時取締役は一定の責任を負わされます。 2

また、募集設立の場合、定款に発起人として署名又は記名押印はしていないものの、株式募集に関する文書等に賛助者として自己の氏名を掲げることを承諾した者（**擬似発起人**）も、発起人と同様の責任を負います（103条4項）。 27-37-オ

(1) 不足額支払責任

現物出資や財産引受の対象である財産の会社成立時の価額が**定款に記載された価額に著しく不足するときは**、発起人や設立時取締役は、会社に対して、連帯してその不足額を支払う義務を負います（52条1項）。 3

もっとも、この責任は発起人等にとって過酷な責任となりが

1 過去問チェック

会社の設立手続が行われたにもかかわらず会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、会社の設立に関して支出した費用を負担する。→
 (19-36-オ)

2 参考

発起人や設立時取締役が、設立に際して発行される株式の引受けや払込みがない部分の引受け・払込みをしなければならないという引受担保責任・払込担保責任は、会社法の成立に伴い廃止されている。 19-36-ウ、26-37-エ

3 具体例をイメージ

例えば、1億円の土地を現物出資する旨が定款に記載されていたにもかかわらず、実際にはその土地が1000万円の価値しかなかった場合、発起人や設立時取締役は、会社に対して9000万円を支払う義務を負う。

ちですから、以下のような場合には免責が認められています。

【不足額支払責任が免責される場合】 図 3-37-1

		検査役の調査を受けた場合	職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明した場合	総株主の同意がある場合
現物出資をした発起人や会社に財産を譲渡した発起人		× (52条2項柱書かつて書)		○ (55条) 図30-37-ア
それ以外の者	発起設立	○ (52条2項)		
	募集設立	○ (52条2項)	× (103条1項)	

○：免責あり、×：免責なし

(2) 任務懈怠責任

① 会社に対する責任

発起人・設立時取締役・設立時監査役は、株式会社の設立について**その任務を怠ったこと**により会社に損害が発生した場合、連帯してその賠償をする責任を負います (53条1項、54条)。

図 3-37-3・5

この会社に対する責任は、**総株主の同意**があれば免除することができます (55条)。図 23-37-4 ※4、30-37-ウ

② 第三者に対する責任

発起人・設立時取締役・設立時監査役がその職務を行うについて**悪意又は重大な過失**があったときは、これによって第三者に生じた損害についても賠償する責任を負います (53条2項)。※5 図 30-37-エ、3-37-4

(3) 出資の履行を仮装した場合の責任 ※6

出資の履行を仮装した発起人や設立時募集株式の引受人は、株式会社に対し、**仮装した金銭の全額**の支払などをする義務を負います (52条の2第1項、102条の2第1項)。図 28-37-ウ、3-37-2

また、出資の履行を仮装することに関与した発起人・設立時取締役も、原則として、同様の義務を負います (52条の2第2項本文、103条2項本文)。

※4 過去問チェック

発起人、設立時取締役または設立時監査役が株式会社の設立にあたり任務を怠り、会社に損害を生じさせた場合には、創立総会の決議によっても、会社に対する責任を免除することはできない。→○ (23-37-4)

※5 引っかけ注意!



第三者に対する責任については、総株主の同意による免除は認められていません。

※6 法改正情報

平成26年の会社法改正により、出資の履行を仮装した場合の責任に関する規定が新設された。

出資の履行を仮装した場合の責任は、**総株主の同意**がなければ、免除することができません（55条、102条の2第2項）。**過**
28-37-ウ、30-37-イ

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ **1** 原始定款は、公証人の認証を受けることによって、その効力を生じる。
- ☐ ☐ ☐ **2** 発起人は、設立時発行株式の引受後遅滞なく、引き受けた株式につき全額の払込み又は全部の給付をしなければならない。
- ☐ ☐ ☐ **3** 株式会社は、発起人及び設立時募集株式の引受人が出資の履行を完了した時点で成立する。
- ☐ ☐ ☐ **4** 設立無効は、いかなる方法によっても主張することができる。

解答 **1** ○（30条1項） **2** ○（34条1項） **3** ×本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する（49条）。 **4** ×訴えによってのみ主張することができる（828条1項柱書）。



学習のPOINT

ここでは、株式会社の特質である株式に関するルールについて学習していきます。株式は、会社法における頻出テーマの1つなので、時間をかけてじっくりと学習しましょう。

1 株主平等の原則

株式会社は、株主をその持株数や有する株式の種類に応じて平等に取り扱わなければなりません（109条1項）。これを**株主平等の原則**といいます。※1 ※2

株主平等の原則に反する定款・契約・決議などは、株主の承認がない限り、**無効**となります。

2 株主の権利

（1）自益権と共益権

株主の権利は、その権利の内容に着目すると、**自益権**と**共益権**に分類することができます。

【自益権と共益権】

	意味	具体例
自益権	会社から経済的利益を受け る権利 ※3	①剰余金配当請求権（105条1項1号） ②残余財産分配請求権（105条1項2号） ③株式買取請求権（192条など）
共益権	会社の経営に 参加する権利	①株主総会における議決権（105条1項3号） ②株主の監督是正権

（2）単独株主権と少数株主権

株主の権利は、その権利を行使する条件に着目すると、**単独株主権**と**少数株主権**に分類することができます。

※1 具体例をイメージ

例えば、株式の内容が同じ場合、1株持っているAに100円の配当と1票の議決権を与えたときは、2株持っているBに200円の配当と2票の議決権を与えなければならない。

※2 参考

非公開会社では、定款の定めにより、剰余金配当請求権・残余財産分配請求権・議決権について、持株数に応じてではなく、株主（人）ごとに異なる取扱いをすることが認められている（109条2項）。図 23-40-2、26-40-1

※3 参考

剰余金配当請求権と残余財産分配請求権の全部を与えない旨の定款の定めは無効（105条2項）となる（どちらか片方を与えないことは可能）。図 23-40-5、30-40-1

【単独株主権と少数株主権】

	意味	具体例
単独株主権	1株しか有していない株主でも行使できる権利	①自益権 ②株主総会における議決権
少数株主権	発行済株式総数の一定割合以上又は総株主の議決権の一定割合以上・一定数以上を有する株主のみが行使できる権利	①株主総会招集請求権 ②役員解任請求権 など

(3) 株式の共有

株式を2人以上の者が共有することが認められていますが、共有者は、共有株式についての権利を行使する者1人を定めて会社にその者の氏名・名称を**通知**しなければ、その株式について権利を行使することができません(106条本文)。

ただし、会社から共有者に権利行使させることを認めることはできます(106条ただし書)。

(4) 株式買取請求権

① 株式買取請求権とは何か

株式買取請求権とは、会社又は株主に重大な影響を与える行為に反対する株主が、会社に対して、その有する株式の買取りを請求することができる権利のことです。これにより、少数派の株主に投下資本回収の道を与えることができます。

② 株式買取請求権を行使できる場合

株式を買い取ることは、会社にとっては本来禁止されている出資の払戻しとなるため、株式買取請求権を行使できる場合は限定されています。

株式買取請求権を行使できる場合としては、以下のようなものがあります。※1 ※2

【株式買取請求権を行使できる場合】 ※3

1	発行する株式全部に譲渡制限の定めを設ける定款変更をする場合(116条1項1号)
2	譲渡制限種類株式・全部取得条項付種類株式とする旨の定款変更をする場合(116条1項2号)

※1 参考

議決権制限株式とする旨の定款変更を行う場合には、株式買取請求権を行使することができない。☞ 19-37-イ

※2 参考

設立時株主は、創立総会における定款変更の決議に反対したとしても、株式買取請求権を行使することはできない。☞ 23-37-5

※3 参考

1～3の場合における株式買取請求により支払った金額が分配可能額を超えた場合、業務執行者はその超過額について責任を負う(464条1項)。☞ 19-37-オ、24-40-4

3	株式の併合・株式の分割・株式無償割当て・単元株制度を採用する旨の定款変更等をする場合など（116条1項3号）
4	事業譲渡（469条）、合併・会社分割（785条、797条、806条）、株式交換（785条、797条）、株式移転（806条）などの組織再編行為をする場合
5	単元未満株式を保有する者（192条） 圖19-37-ア、27-38-3

③ 手続 ※4

株式買取請求権を行使するためには、株主総会の決議に先立ち**反対する旨を会社に通知**し、かつ、株主総会でも**議案に反対の議決権行使**をしなければなりません（116条2項1号イ）。 圖19-37-ウ ※5

ただし、議決権のない株主（議決権制限株式）は、そもそも株主総会に参加することができませんから、上記の手続を経ずに株式買取請求をすることができます（116条2項1号ロ）。

3 株式の内容

株式会社は、**定款**で定めることにより、①株式全部の内容として特別な事項を定めること（107条1項）や、②内容の異なる複数の種類の株式を発行すること（**種類株式**：108条1項）ができます。これは、株式を通じて多様な支配関係や資金調達を確保できるようにするためです。

（1）株式全部の内容

株式全部の内容として定めることができるものは、**譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式**の3つです。

【株式全部の内容】

譲渡制限株式	譲渡による取得について会社の承認が必要な株式 圖30-38-1
取得請求権付株式	株主の方から会社に対してその株式の取得を請求することができる権利が付与された株式 圖2-38-1
取得条項付株式	会社が株主の同意なしに一定の事由が生じたことを条件として取得できる条項が付与された株式 圖2-38-2

（2）種類株式

種類株式についても、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取

※4 参考

株式の買取りを会社に対して請求した株主であっても、会社の承諾があれば、買取請求を撤回することができる（116条7項）。 圖19-37-エ

※5 過去問チェック

株主総会決議に反対する株主が買取請求権を行使するには、原則として、その決議に先立ち反対の旨を会社に通知し、かつ、その総会において反対しなければならない。→○（19-37-ウ）

得条項付株式の3つを定めることができます。また、これらに加えて、以下のようなものがあります。📖28-38-ウ・エ、30-38-1、2-38-1・2

【種類株式】

優先株・劣後株	剰余金の配当や残余財産の分配について異なる定めをした株式であり、優先的な取扱いをするものを優先株、劣後的な取扱いを受けるものを劣後株という
議決権制限株式	株主総会で議決権を行使できる事項について異なる定めをした株式 📖28-38-イ
全部取得条項付株式	その種類株式の全部を株主総会の特別決議で取得できる旨を定めた株式 📖28-38-ア
拒否権付株式	株主総会の決議事項につき、当該決議に加えて、拒否権付株式を持っている者だけで構成される種類株主総会の決議も必要となる株式
取締役・監査役の選任権付株式	その種類株式を持っている株主だけで構成される種類株主総会で取締役と監査役の選任をすることができる株式 ※1 ※2

4 株式の譲渡

(1) 株式譲渡自由の原則

株式会社では出資の払戻しが認められていないため、株式の譲渡により出資金を回収する機会を確保する必要があります。また、株式会社では株主の個性が重視されないため、株式の譲渡がなされても会社に不都合は生じません。そこで、株主は、原則として、その有する株式を自由に譲渡することができます(127条)。これを**株式譲渡自由の原則**といいます。📖29-40-イ

(2) 法律による株式の譲渡制限

例外的に、法律により株式の譲渡が制限されている場合があります。具体的には、以下のようなものがあります。

① 権利株の譲渡制限

権利株（会社の成立前又は新株 ※3 発行前の株式引受人の地位）の譲渡は、会社に対抗することができません（35条、63条2項、208条4項）。なお、権利株の譲渡も、当事者間では有効となります。

※1 具体例をイメージ

例えば、AとBが会社を設立した場合に、その出資割合に応じてAが選任したい取締役2人を、Bが選任したい取締役1人を選ぶというような形で利用できる。

※2 参考

取締役・監査役の選任権付株式は、支配権濫用の危険が大きいことから、会社運営の自由度が高い非公開会社では発行できるが、指名委員会等設置会社と公開会社では発行することができない（108条1項ただし書）。📖28-38-オ

※3 用語

新株：会社の成立後に発行される株式のこと。

※4 引っかけ注意!



権利株の譲渡は会社に対抗できない（会社の側から譲渡を有効と認めることはできる）のに対し、株券発行前の譲渡は会社に対して効力を生じない（会社の側から譲渡を有効と認めることはできない）とされている。

② 株券発行前の譲渡制限

株券発行会社における**株券発行前**の株式の譲渡は、会社に対して効力を生じません（128条2項）。なお、株券発行前の株式の譲渡も、当事者間では有効となります。※4

③ 子会社による親会社株式の取得制限

子会社は、原則として、**親会社**の株式を取得することができません（135条1項）。

ただし、**組織再編行為**（事業譲渡・合併・会社分割）により他の会社から親会社株式を承継する場合等には親会社株式の取得が認められます（135条2項）。図23-38-5

もっとも、子会社が例外的に親会社株式を取得することになった場合は、**相当の時期**にその有する親会社株式を処分しなければなりません（135条3項）。図23-38-5

④ 自己株式 ※5 の取得制限

自己株式の取得は、実質的に出資の払戻しにあたることになり会社債権者を害するなどの弊害があります。そこで、会社法は、会社が自己株式を取得することができる場合を限定しています（155条）。※6 ※7

自己株式の取得手続は、以下のとおりです。

【自己株式の取得手続】

すべての株主に申込機会を与える場合	株主総会の普通決議が必要（156条1項）
特定の株主から取得する場合	株主総会の特別決議が必要（160条1項、309条2項2号）※8 図23-38-4
子会社から取得する場合	取締役会設置会社では 取締役会決議 、取締役会非設置会社では 株主総会の普通決議 で足りる（163条）
市場取引等により取得する場合	取締役会設置会社では、 取締役会の決議 によって定めることができる旨を 定款 で定めることができる（165条2項） 図2-38-4

会社は、自己株式を期間制限なく保有することができます。

また、自己株式を再利用しない場合には、自己株式を**消却** ※9 することができます（178条）。

※5 用語

自己株式：その会社自身の株式のこと。

※6 参考

株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には、当該株式会社は、当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得することができる（155条10号）。図2-38-3

※7 参考

会社債権者や既存株主の利益を害しないようにするため、自己株式の有償取得は、分配可能額の範囲内でのみ認められる（461条1項1号～7号）。図2-38-5

※8 参考

取得の相手方となる特定の株主は、原則として、自己株式取得を承認するかどうかを決定する株主総会で議決権を行使することができない（160条4項）。図25-38-5

※9 用語

消却：発行済株式を回収して、これを絶対的に消滅させること。

(3) 定款による株式の譲渡制限

① 定款による株式の譲渡制限とは何か

株式会社は、株式を譲渡するには会社の承認を得なければならない旨を定款で定めることができます（107条1項1号、108条1項4号）。このような株式を**譲渡制限株式**といいます。**※1 ※2**

② 承認機関

定款による株式の譲渡制限を設けた場合、株式を譲渡するには、取締役会設置会社では**取締役会**の承認を必要とし、それ以外の会社では**株主総会の普通決議**による承認を必要とするのが原則です（139条1項本文）。**23-38-2**

ただし、定款で別段の定めを置くこともできます（139条1項ただし書）。**※3**

(4) 株式の譲渡方法と対抗要件

株式の譲渡方法及び対抗要件は、株券発行会社か株券不発行会社かによって異なります。

株式の譲渡は、会社に対する権利の譲渡ですから、その対抗要件は第三者に対するものだけでなく、会社に対する対抗要件も必要となります。

【株式の譲渡方法と対抗要件】

	株式の譲渡方法	第三者への対抗要件	会社への対抗要件
株券発行会社	意思表示の合致＋株券の交付（128条1項本文）	株券の交付 21-38-ウ	株主名簿の名義書換 ※4 （130条2項） ※5 ※6
株券不発行会社	意思表示の合致	株主名簿の名義書換（130条1項）	

5 出資単位の調整

1株の価格（出資単位）が高すぎると個人投資家は手を出しにくくなり、1株の価格が低すぎると株主の数が多くなって事務処理の費用がかさんでしまいます。そこで、1株の価格をいくりにするかは、会社にとって重要な問題となります。

出資単位を調整する手段としては、(1)**株式の併合**、(2)**株式の**

※1 重要判例

会社の承認を受けないでなされた譲渡制限株式の譲渡は、当該株式会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡の当事者間では有効である（最判昭48.6.15）。**23-38-3**

※2 参考

合併や会社分割などの一般承継による株式の取得について、定款において、会社の承認を要する旨の定めをすることはできない。**23-38-1**

※3 具体例をイメージ

例えば、代表取締役を承認機関とすることもできる。

※4 用語

名義書換：株式を取得した者の氏名・名称・住所を株主名簿に記載・記録すること。

※5 重要判例

株主名簿の名義書換がなくても、会社の側から取得者を株主と扱うことはできる（最判昭30.10.20）。**21-38-イ**

※6 重要判例

会社が株主による株主名簿の名義書換請求を不当に拒絶した場合には、当該株主は、会社に対して、株主であることを主張することができる（最判昭42.9.28）。**21-38-エ**

分割、(3)株式無償割当て、(4)単元株制度の4種類があります。

(1) 株式の併合

株式の併合とは、数個の株式を合わせてそれよりも少数の株式とすることです(180条1項)。これにより、1株の値段を従来の倍以上にでき、株価をつり上げることができます。※7

株式併合を行うためには、**株主総会の特別決議**が必要となります(180条2項、309条2項4号)。このように厳格な手続が必要とされているのは、例えば2株を1株にした場合に、もともと1株しか持っていない者は端数だけの株主となってしまう、不利益を生じさせるからです。図26-38-1

(2) 株式の分割

株式の分割とは、既存の株式を細分化して従来よりも多数の株式とすることです(183条1項)。これにより、1株の値段を従来の半額以下とすることができ、株価が高すぎて市場で取引されにくい場合に、流通性を高めることができます。※8

株式の分割の場合、特に株主の利益を害しないので、**株主総会の普通決議**(取締役会設置会社では**取締役会決議**)で行うことができます(183条2項)。※9 図26-38-2

(3) 株式無償割当て

株式無償割当てとは、株主に対して無償で(新たに払込みをさせないで)新株・自己株式の割当てをすることです。これにより、株式の分割をしたのと同様の効果が生じます。※10 ※11

株式無償割当ては、**株主総会の普通決議**(取締役会設置会社では**取締役会決議**)で行うことができます(186条3項)。図26-38-3

(4) 単元株制度

① 単元株制度とは何か

単元株制度とは、株式の一定数をまとめたものを1単元として、その1単元につき1個の議決権を認める制度のことです。これは、株主総会の招集通知の発送等にかかる株主管理コストを削減するための制度です。※12

単元株制度を採用しようとする会社は、その旨を**定款**で定める必要があります(188条1項)。図27-38-1

※7 具体例をイメージ

例えば、従来の2株を1株にする場合などである。

※8 具体例をイメージ

例えば、従来の1株を2株にする場合などである。

※9 参考

株式分割を行う場合、株主総会決議によらないで、発行可能株式総数を一定限度で増加させる定款変更をすることができる(184条2項)。図26-38-4

※10 具体例をイメージ

例えば、株主が保有している1株につき0.5株を無償で交付する場合などである。

※11 参考

会社が複数の種類の株式を発行している場合、異なった種類の株式を割り当てることも可能である(186条1項1号)。

※12 具体例をイメージ

例えば、100株を1単元とし、1単元につき1個の議決権を認める場合などである。

② 単元未満株主の権利

単元未満株式については、議決権が認められませんから、株主提案権（303条）などの議決権を前提とする権利も認められません。ただし、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権などの**自益権**は認められます（189条2項）。※1 27-38-2

③ 単元株制度を採用・廃止する手続

1単元の株式の数を増加する場合には、**株主総会の特別決議**による定款変更が必要です（466条、309条2項11号）。

これに対して、1単元の株式の数を減少する場合や、単元株制度を廃止する場合には、**取締役の決定**（取締役会設置会社では**取締役会決議**）により行うことができます（195条1項）。27-38-5

出資単位の調整の手続についてまとめると、以下の表のようになります。

【出資単位の調整の手続】

		取締役会設置会社	取締役会非設置会社
株式併合		株主総会の特別決議 (180条2項、309条2項4号)	
株式分割		取締役会決議 (183条2項)	株主総会の普通決議 (183条2項)
株式無償割当て		取締役会決議 (186条3項)	株主総会の普通決議 (186条3項)
単元株制度	採用・増加	株主総会の特別決議による定款の変更が必要 (466条、309条2項11号)	
	廃止・減少	取締役会決議 (195条1項)	取締役の決定 (195条1項)

6 株券

(1) 株券の発行

株券とは、株主の地位を表す有価証券のことです。

株券は、原則として**発行しない**こととされており、定款で株券を発行すると決めた場合に限って発行することができます（214条）。このように、株券の不発行が原則とされたのは、株券を発行しないほうが株式の取引を迅速に行うことができるか

※1 参考

単元未満株主は、定款の定めるところにより、自己の所有する単元未満株式の数と併せて単元株式となる数の株式を自己に売り渡すことを会社に請求できる（194条1項）。27-38-4

からです。※2 図26-40-3

(2) 善意取得

株券の占有者は、**適法な所持人**と推定されます（131条1項）。そして、株券の占有者から株券の交付を受けた者は、悪意又は重大な過失がない限り株式を取得できます（131条2項）。これを**善意取得**といいます。

(3) 株主の保護

株券を紛失した場合、その株券を手に入れた者が善意・無重過失の第三者に譲渡してしまうと、先ほど説明した善意取得により株式を取得されてしまい、元の株主は株式を失うことになります。こういったことをあらかじめ防止するために、以下のような制度が設けられています。

① 株券不所持制度

株主は、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができま
す（217条1項）。これを**株券不所持制度**といいます。※3

② 株券失効制度

株主は、株券を紛失した場合、会社に対して**株券喪失登録簿**に記載・記録することを請求することができます（221条～223条）。喪失登録されている株券については、名義書換や議決権行使が制限され、その登録後1年を経過すると、当該株券は無効となります。これを**株券失効制度**といいます。※4

7 株主名簿

(1) 株主名簿の作成

株主名簿とは、株主に関する事項を記載・記録した帳簿のことです。

株式会社では、株主名簿の作成が義務付けられ、これに①株主の氏名・名称及び住所、②株主の有する株式の数、③株主が株式を取得した日、④株券発行会社では株式に係る株券の番号を記載・記録しなければなりません（121条）。これは、大規模な株式会社では、多数の株主が全国に散らばっていることが多いので、どこの誰が株主であるかを把握するために必要だからです。※5 図21-38-ア

※2 参考

株券を発行する旨を定款に定めた会社は、原則として、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならないが（215条1項）、非公開会社の場合、株主から株券の発行を請求された段階で初めて株券を発行すれば足りる（215条4項）。
図21-37-2

※3 参考

不所持の申出があった株券は不発行状態となり、すでに発行されている場合には、その株券は無効なものとなる。

※4 参考

何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿（利害関係がある部分に限る）について、閲覧の請求をすることができる（231条2項本文）。
図20-36-4

※5 参考

会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載・記録された株主の住所又は株主が別に通知した場所・連絡先に宛てて発すれば足り（126条1項）、当該通知又は催告は、それが通常到達すべきであった時に、到達したものとみなされる（126条2項）。
図21-38-オ

(2) 基準日

株式会社は、一定の日（これを**基準日**といいます）を定めて、基準日において株主名簿に記載・記録されている株主（これを**基準日株主**といいます）を、その権利を行使することができる者と定めることができます（124条1項）。※1 図 2-39-1

ただし、基準日株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合には、株式会社は、基準日株主の権利を害することがない範囲であれば、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を株主総会における議決権を行使することができる者と定めることができます（124条4項）。図 2-39-2

(3) 株主名簿の閲覧・謄写 ※2

株主・債権者は、株式会社の**営業時間内**はいつでも、株主名簿の閲覧・謄写を請求することができます（125条2項）。図 20-36-1

これに対して、親会社社員は、**その権利を行使するため必要**があるときに限り、**裁判所の許可**を得て、株主名簿の閲覧・謄写を請求することができます（125条4項）。

8 募集株式の発行等

(1) 募集株式の発行等とは何か

募集株式の発行等とは、①新株の発行及び②自己株式の処分をまとめた概念です。これらは、会社成立後の資金調達の方法としてなされるものです。

募集株式の発行等の態様には、株主の持株数に応じて株式の割当てを受ける権利を与える場合（**株主割当て**）と、株主以外の第三者に株式の割当てを受ける権利を与える場合（**第三者割当て**）の2つがあります。※3

(2) 手続

① 募集事項の決定

募集株式の発行等を行う場合、募集株式の数・払込金額などの募集事項を決定しなければなりません。

募集事項の決定を行う機関は、以下のとおりです。※4

※1 参考

株主総会においてその延期または続行について決議があった場合には、株主総会の招集に関する規定は適用されないことから（317条）、株式会社は改めて招集手続をとる必要はなく、新たな基準日を定める必要もない。

図 2-39-4

※2 用語

謄写：書き写すこと。なお、実際にはコピーを利用することがほとんどである。

※3 参考

株主に割り当てる場合でも、持株比率に応じて割り当てるのでなければ、第三者割当てになります。

※4 参考

払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合、株主総会の特別決議が必要であり、取締役は、その株主総会において、理由を説明しなければならない（199条3項、201条1項、309条2項5号）。

【募集事項の決定機関】

		株主割当て	第三者割当て
非公開会社	原則	株主総会の特別決議	
	例外	定款の定めにより、取締役の決定（取締役会設置会社にあつては、取締役会決議）とすることができる	株主総会の特別決議により、取締役の決定（取締役会設置会社にあつては、取締役会決議）に委任することができる
公開会社		取締役会決議 図22-37-1、25-40-1、29-40-ウ	

② 出資の履行

募集株式の引受人は、払込期日又は払込期間内に、株式会社
が定めた銀行等の払込取扱場所において、**募集株式の払込金額
の全額**を払い込み（208条1項）、又はそれに相当する**現物出資
財産を給付**しなければなりません（208条2項）。※5

そして、募集株式の引受人が出資の履行をしないときは、当
該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失
います（208条5項）。

③ 株主となる時期

募集株式の引受人は、払込期日が定められたときは**その払込
期日**に、払込期間が定められたときは**出資を履行した日**に、出
資の履行をした募集株式の株主となります（209条1項）。

（3）違法な募集株式の発行等に対する措置

① 株主による差止め請求

募集株式の発行等が法令・定款に違反し、又は著しく不正な
方法により行われる場合において、**株主**が不利益を受けるお
それがあるときは、株主は、株式会社に対し、**募集株式の発行
等の差止め**を請求することができます（210条）。

② 無効の訴え

募集株式の発行等の無効は、効力が生じた日から**6ヶ月以内**
（非公開会社の場合は**1年以内**）に、訴えをもってのみ主張す
ることができます（828条1項2号・3号）。

無効原因に当たるかどうかについては、以下のとおりです。

※5 参考

募集株式の引受人
は、出資の履行をす
る債務と会社に対す
る債権とを相殺する
ことができない(208
条3項)。

【募集株式の発行等の無効原因】

無効原因に当たる	無効原因に当たらない
①発行可能株式総数を超えて新株を発行した場合 ②募集株式の発行等の公告・通知をしなかった場合（募集株式発行差止め請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれが許容されないと認められる場合を除く：最判平9.1.28）	①代表取締役が有効な取締役会決議を経ないで新株を発行した場合（最判昭36.3.31） ②株主総会の特別決議を経ないで第三者に対して有利発行が行われた場合（最判昭46.7.16）

9 新株予約権

（1）新株予約権とは何か

新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより、当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利のことです（2条21号）。要するに、株式の引換券のようなものです。

新株予約権者により新株予約権が行使された場合、株式会社は、新株予約権者に対して、新たに株式を発行するか、自己株式を交付する義務を負うことになります。

（2）募集新株予約権の発行

① 手続

募集新株予約権の発行は、募集株式の発行等の場合と同様の手続を経る必要があります。^{※1}

ただし、新株予約権者となる時期は、募集株式の発行等の場合と異なり、**割当日**です（245条1項）。^{図22-38-ア ※2}

② 違法な募集新株予約権の発行に対する措置

募集株式の発行等の場合と同様に、株主による**差止め請求**が認められています（247条）。^{図22-38-ウ ※3}

また、**無効の訴え**も同様に認められています（828条1項4号）。

（3）新株予約権の譲渡

新株予約権者は、原則として、その有する新株予約権を自由に**譲渡**することができます（254条1項）。

もっとも、**新株予約権付社債**^{※4}を有する者は、その新株予

※1 参考

募集新株予約権の募集事項は、非公開会社は株主総会の特別決議で（238条2項、309条2項6号）、公開会社は取締役会決議で決定しなければならないのが原則である（240条1項）。しかし、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合にそれが特に有利な条件となるとき、又は募集新株予約権の払込金額が特に有利な金額であるときは、株主総会の特別決議で決定しなければならない（238条3項）。^{図22-38-イ}

※2 過去問チェック

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する募集新株予約権を発行する場合において、募集新株予約権の割当てを受けた者は、払込期間中または払込期日に払込金額の全額を払い込んだときに、新株予約権者となる。→**×**（22-38-ア）

※3 過去問チェック

募集新株予約権の発行が法令もしくはは定款に違反し、または著しく不正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときには、株主は、会社に対して募集新株予約権の発行をやめることを請求することができる。→**○**（22-38-ウ）

約権付社債についての社債が消滅した場合を除き、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできません(254条2項)。㊦22-38-工

(4) 新株予約権の行使

新株予約権者は、会社に対して、新株予約権の内容・数・行使の日を明らかにして、新株予約権を行使することができます(280条1項)。

新株予約権者は、**新株予約権を行使した日**に、その新株予約権の目的である株式の株主となります(282条1項)。㊦5

※4 用語

社債：会社を債務者とする金銭債権のこと。

※5 参考

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する募集新株予約権の払込金額は、新株予約権が行使された場合に初めて、資本金に計上しなければならない(445条1項)。㊦22-38-オ

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ **1** 会社は、株主をその持株数や有する株式の種類に応じて平等に取り扱わなければならない。
- ☐ ☐ ☐ **2** 子会社は、原則として、親会社の株式を取得することができる。
- ☐ ☐ ☐ **3** 株式会社は、株式を譲渡するには会社の承認を得なければならない旨を定款で定めることができる。
- ☐ ☐ ☐ **4** 株券は、原則として、発行しなければならない。

解答 **1** ○ (株主平等の原則：109条1項) **2** × 子会社は、原則として、親会社の株式を取得することができない(135条1項)。 **3** ○ (107条1項1号、108条1項4号) **4** × 株券は、原則として、発行する必要はなく、定款で株券を発行すると決めた場合に限り発行することができる(214条)。



学習のPOINT

機関は、会社法の中でも断トツで出題頻度が高いテーマですから、しっかりと学習しておきましょう。特に、株主総会・取締役・取締役会・役員等の責任に重点を置くとよいでしょう。

1 機関設計

機関とは、会社の代わりに意思決定や行為をする人及びその集まり（合議体）のことです。これは、行政組織法のところで学習した行政主体と行政機関の關係に類似しています。つまり、行政主体に当たるのが会社であり、行政機関に当たるのが機関といえます。

株式会社には、必ず**株主総会**と**取締役**を置かなければなりませんが（295条、326条1項）、その他の取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人・監査等委員会・指名委員会等については、定款で定めることにより自由に置くことができます（326条2項）。図19-38-5

もっとも、完全に自由な機関設計を認めているわけではなく、以下のような一定のルールが定められています。

【機関設計のルール】

取締役会を置かなければならない会社	公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社（327条1項） 図 28-39-3
監査役を置かなければならない会社	取締役会設置会社、会計監査人設置会社（327条2項・3項） ※1 ※2
監査役会を置かなければならない会社	公開会社である大会社 ※3 （328条1項）
会計監査人を置かなければならない会社	監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、大会社（327条5項、328条1項・2項） 図 28-39-5、2-40-4

※1 参考

非公開会社で任意に取締役会を設置している会社の場合、会計参与を置けば、監査役を置く必要はない（327条4項）。図28-39-1

※2 参考

監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社では、監査役を置くことができない（327条4項）。図28-39-1

※3 用語

大会社：最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上又は負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である株式会社のこと（2条6号）。

2 株主総会

(1) 権限

株主総会とは、会社の構成員である株主によって構成され、会社の意思を決定するための機関のことです。

株主総会の権限は、取締役会設置会社であるか取締役会非設置会社であるかによって異なります。

【株主総会の権限】

取締役会 非設置会社	会社法に規定する事項及び株式会社の組織・運営・管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる（295条1項） 図元-40-1
取締役会 設置会社	会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議することができる（295条2項） 図26-39-1

(2) 招集手続

① 招集地

会社法の下では、株主にとって特に不利益とならない限り、株主総会を開催する場所に制限はありません。

② 招集時期

株主総会には、毎事業年度 **※4** の終了後一定の時期に招集される**定時株主総会**（296条1項）と、必要に応じて随時招集される**臨時株主総会**（296条2項）とがあります。

③ 招集権者

取締役会設置会社では、**取締役会**の決議（298条4項）に基づいて、**代表取締役**名義で招集通知を出します。これに対して、取締役会非設置会社では、**取締役**が決定し招集通知を出します（296条3項）。**※5**

もっとも、少数株主権として、一定の株式数を保有する株主にも株主総会の招集を請求する権利が認められています（297条）。図24-38-1

④ 招集通知

株主総会の招集通知については、以下の表のような規制があります。

※4 用語

事業年度：会社の収支決算を明らかにするための区切りとなる期間のこと。一般に、1月1日又は4月1日から1年又は半年とされている。

※5 重要判例

代表取締役以外の取締役によって招集された株主総会は、招集権限のない者により招集されたものであって、法律上の意義における株主総会ということとはできず、株主総会決議があったものとはいえない（不存在である）（最判昭45.8.20）。図25-38-2

【株主総会の招集通知】

	公開会社、書面投票・電子投票を定めた会社	それ以外の会社
発出時期	2週間前	1週間前 (取締役会非設置会社の場合、定款で短縮可能)
通知の方法	書面によらなければならない※1 図2-40-3	取締役会設置会社の場合、書面によらなければならないが、取締役会非設置会社の場合、制限なし

⑤ 招集手続の省略

書面・電磁的記録による議決権行使を認める場合（298条1項3号・4号）を除いて、**株主全員の同意**があれば、招集手続なしに株主総会を開催することができます（300条）。※2

⑥ 株主総会資料の電子提供制度

株主総会資料の電子提供制度とは、株主総会資料を自社のWebサイトに掲載し、株主に当該Webサイトのアドレス等を書面で通知することで提供する制度のことです（325条の2）。資料の掲載日は、株主総会の日の3週間前又は招集の通知を発した日のいずれか早い日です（325条の3第1項）。

（3）議事

① 株主提案権

株主には、以下のような権利が認められています。これらをまとめて**株主提案権**といいます。

【株主提案権】

議題提案権	一定の事項を議題とするよう請求する権利（303条1項）
議案提出権	株主総会の会日において、株主総会の目的である事項についての議案を提出する権利（304条）
議案の要領の通知請求権	あらかじめ取締役に対して議案を提案して、それを招集通知に記載するよう請求する権利（305条1項）※3

② 取締役等の説明義務

取締役等は、株主から説明を求められた場合には、必要な説明をしなければなりません（314条本文）。

ただし、以下の場合には取締役は説明を拒むことができます。

※1 参考

株主の承諾があれば、電磁的方法（電子メール）で通知することもできる（299条3項）。

※2 重要判例

招集権者による株主総会の招集の手続を欠く場合であっても、株主全員がその開催に同意して出席したいいわゆる全員出席総会において、株主総会の権限に属する事項について決議をしたときには、この決議は株主総会の決議として有効に成立する（最判昭60.12.20）。図18-38-1、25-38-1

※3 法改正情報

令和元年の会社法改正により、取締役会設置会社においては、提出しようとする議案の数が10を超えるときは、10を超えた分については議案の要領の通知請求をすることができない、という数の制限が設けられた（305条4項）。

【取締役が説明を拒否できる場合】

1	株主の質問事項が株主総会の目的である事項（議題）に関しないものである場合
2	その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合（説明をすることで企業秘密が外部に漏れてしまうような場合）
3	正当な理由がある場合として法務省令で定める場合（説明をするのに調査が必要で、その場ですぐに回答するのが困難な場合等）

③ 総会検査役

株式会社又は総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主は、株主総会の招集手続及び決議方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができます（306条1項）。これによって選任された者を**総会検査役**とといいます。図19-38-1 ※4

④ 議事録

株主総会が終結した場合には、当該議事について**議事録**を作成しなければなりません（318条1項）。※5

そして、株主・会社債権者は、会社の**営業時間内**はいつでも、株主総会議事録の閲覧・謄写請求をすることができます（318条4項）。これに対して、親会社社員は、**権利行使に必要**なときに限り、**裁判所の許可**を得て、閲覧・謄写請求をすることができます（318条5項）。

⑤ 決議の省略

ある提案について、議決権を行使できる株主全員が書面・電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、**提案を可決する決議**があったものとみなされます（319条1項）。図26-39-3

その場合、決議があったとみなされた日から**10年間**、同意の書面・電磁的記録を本店に備え置いて、株主等が閲覧できるようにしておく必要があります（319条2項～4項）。

（4）議決権

① 1株1議決権の原則

各株主は、原則として、その有する1株について1個の議決権を持ちます（308条1項本文）。これを**1株1議決権の原則**とといいます。※6 図元-38-1

※4 過去問チェック

株主総会の招集手続および決議方法を調査するため、総会検査役が選任されることがある。→○（19-38-1）

※5 参考

株主総会議事録は、株主総会の日から本店に10年間、写しを支店に5年間備え置かなければならない（318条2項・3項本文）。

※6 参考

株式会社は、1株に複数の議決権を有する種類株式を発行することはできない。図18-40-1

もっとも、以下の場合には例外が認められています。

【1株1議決権の原則の例外】

単元未満株式	単元株制度が採用されている場合、単元未満株式については議決権が認められない（308条1項ただし書）
議決権制限株式	議決権制限株式を有する株主は、制限された事項について議決権を行使することができない（108条1項3号）
自己株式	会社が保有する自己株式については、議決権が認められない（308条2項）
子会社の保有する親会社株式	子会社が親会社株式を保有する場合、原則として、当該株式については議決権が認められない（308条1項本文かつこ書）
相互保有株式	総株主の議決権の4分の1以上の議決権を保有されている会社（被支配会社）は、支配会社の株式について議決権を行使することができない（308条1項本文かつこ書）

② 代理人による議決権行使

株主は、**代理人**によって議決権を行使することができます（310条1項前段）。※1 図2-39-3

この代理権の授与は、株主総会ごとにしなければなりません（310条2項）。図2-39-3

③ 議決権の不統一行使

株主は、その有する議決権を**統一しないで**行使することができます（313条1項）。※2

もっとも、これは他人のために株式を有する者のために必要とされる制度ですから、会社は、他人のために議決権を有する者でない者が不統一行使をしたときは、これを拒むことができます（313条3項）。

④ 書面投票・電子投票制度

会社側から、株主総会の招集通知に株主総会参考書類と議決権行使書面を添付して株主へ送付し、株主が議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会直前の営業時間終了時までには会社に提出した場合には、議決権を行使したものと扱うことができます（311条1項）。これを**書面投票制度**といいます。※3

また、以上の投票方式を電磁的方法によって行う場合、これ

※1 重要判例

株主総会において議決権を行使する代理人を株主に限る旨の定款の規定は、株主総会が第三者により攪乱されることを防止して、会社の利益を保護する趣旨に出た合理的理由による相当程度の制限であるから、有効である（最判昭43.11.1）。図18-38-2、21-37-3、25-38-4

※2 具体例をイメージ

例えば、信託会社が複数の委託者のために株式を保有しており、議決権の行使についてある委託者からは議案に賛成するよう指図を受け、他の委託者からは議案に反対するよう指図を受けた場合などである。

※3 参考

書面投票制度は、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができるものであるから（298条1項3号）、株主が議決権行使書面を送付した場合に、当該株主が株主総会に出席して議決権を行使したときには、書面による議決権行使の効力は失われる。図2-39-5

を**電子投票制度**といいます（312条）。

(5) 決議方法 ※4

株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うのが原則です（309条1項）。これを**普通決議**といいます。

ただし、取締役・会計参与・監査役の選任、取締役・会計参与の解任の決議については、定款の別段の定めによっても、定足数を**3分の1未満**の割合にすることができません（341条）。

なお、会社法は、一定の重大事項について、普通決議よりも厳格な決議要件である**特別決議**（309条2項）、**特殊決議**（309条3項）、**特別特殊決議**（309条4項）を定めています。

【株主総会の決議方法】

	要件	決議事項
特別決議	議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成	通常の定款変更など
特殊決議	議決権を行使できる株主の半数以上の賛成、かつ、議決権を行使できる株主の議決権の3分の2以上の賛成	発行する株式全部に譲渡制限を付するための定款変更 図25-37-ア
特別特殊決議	総株主の半数以上の賛成、かつ、総株主の議決権の4分の3以上の賛成	非公開会社が剰余金の配当・残余財産の分配・議決権について、株主ごとに異なる取扱いを定める定款変更

(6) 株主総会決議の瑕疵 ※5

株主総会の決議に瑕疵があった場合、会社法が認めている救済方法としては、**株主総会決議取消しの訴え**（831条）、**決議不存在確認の訴え**（830条1項）、**決議無効確認の訴え**（830条2項）の3種類があります。

※4 参考

取締役会設置会社においては、株主総会は、招集権者が株主総会の目的である事項として株主に通知した事項（298条1項2号）以外の事項については、決議をすることができない（309条5項）。他方、取締役会非設置会社の株主総会においては、このような制限はない。図26-39-2

※5 参考

会社を被告とする株主総会の決議取消しの訴え、決議の無効確認の訴え、及び決議の不存在確認の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する（838条）。図26-39-5

【株主総会決議の瑕疵を争う方法】

	決議取消しの訴え	決議無効確認の訴え	決議不存在確認の訴え
提訴原因	①招集手続又は決議方法が法令・定款に違反し、又は著しく不公正なとき ※1 ②決議内容が定款に違反するとき ③特別利害関係人が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたとき	決議内容が法令に違反するとき ※2 25-38	決議の手続的瑕疵が著しく、法律上決議があったと認められないとき ※3
提訴権者	株主・取締役・執行役・監査役・清算人 2元-38-4	誰でも提訴できる	誰でも提訴できる
提訴期間	決議の日から3ヶ月以内 ※4	いつでも提訴できる	いつでも提訴できる
裁量棄却 ※5	招集手続又は決議方法の法令・定款違反の場合のみ可能	不可	不可

3 取締役

(1) 取締役とは何か

取締役会非設置会社の場合、取締役は、会社の業務を執行する機関です。これに対して、取締役会設置会社の場合、取締役は、単なる取締役会の構成員にすぎず、会社の業務を執行する機関ではありません。

株主は、経営に興味がない場合や経営の能力がない場合がほとんどですので、自分で会社の経営をせずに、経営のプロである取締役を選任してその人に経営を任せる方が望ましいといえます。これを**所有と経営の分離**といいます。

そこで、公開会社は、取締役が株主でなければならない旨を**定款**で定めることができないとされています（331条2項本文）。もっとも、非公開会社では、このような定款の定めをすることもできます（331条2項ただし書）。21-40-1、25-38-1、元-40-4、2-40-5

※1 重要判例

株主は、自己に対する株主総会の招集手続に瑕疵がなくとも、他の株主に対する招集手続に瑕疵があるときは、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる（最判昭42.9.28）。18-38-3

※2 重要判例

株主総会の決議の内容自体に法令・定款違背の瑕疵がなく、単に決議の動機・目的において公序良俗に違反する不法がある場合、その株主総会の決議は無効とはならない（最判昭35.1.12）。18-38-5

※3 具体例をイメージ

例えば、取締役会の決議がないのに平取締役が勝手に招集した場合や、招集通知がまったくなかったと同視できるほどに招集通知漏れがあった場合などである。

※4 重要判例

提訴期間が経過した場合、新たな取消事由を追加して主張することはできない（最判昭51.12.24）。18-38-4

(2) 資格

以下の者は、取締役になることができません（331条1項）。※6

【取締役の欠格事由】

1	法人
2	会社法秩序に関する犯罪を犯し、刑に処せられて間もない者
3	その他の法令違反により禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わっていない者

なお、成年被後見人が取締役に就任するには、その成年被後見人が、**成年被後見人の同意**（後見人監督人がある場合は後見監督人の同意も必要）を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をすることになります（331条の2第1項）。また、被保佐人が取締役に就任するには、その**保佐人の同意**を得なければなりません（331条の2第2項）。※7

(3) 員数

取締役会を設置しない会社であれば、**1人**でも足りませんが、取締役会設置会社では**3人以上**が必要です（331条5項）。図元-40-3

(4) 選任

取締役は、**株主総会の普通決議**によって選任されます（329条1項、341条）。

(5) 終任

① 任期満了

取締役の任期は、原則として、選任後**2年**以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです（332条1項本文）。もっとも、定款又は株主総会決議で**短縮**することは可能です（332条1項ただし書）。図25-38-3

② 株主総会決議による解任

取締役は、いつでも、**株主総会の普通決議**により解任することができます（339条1項、341条）。

もっとも、累積投票 ※8 により選任された取締役又は監査等委員である取締役であれば**株主総会の特別決議**が必要です（309条2項7号）。

株主総会の決議によって解任された取締役は、その解任につ

※5 用語

裁量棄却：形式的に招集手続や決議方法の法令違反が認められるものの、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさない場合に、請求を棄却すること（831条2項）。図26-39-4

※6 引っかけ注意!



未成年者や破産手続開始決定を受け復権していない者であっても、取締役にすることができます。

※7 法改正情報

従来、成年被後見人・被保佐人は、取締役にすることができないとされていたが、令和元年の会社法改正により、一定の要件を満たすことで取締役にできるようになった。

※8 用語

累積投票：株主に対して選任する取締役の数と同数の議決権を与えて、株主は、1人のみに投票するか又は2人以上に投票して、その中で最多数を得た者から順次取締役に選任されるものとする方法のこと。

いて**正当な理由**がある場合を除き、株式会社に対して、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます（339条2項）。

③ 取締役解任の訴え

取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令・定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該取締役を解任する旨の議案が株主総会で否決された場合には、株主は、当該株主総会の日から**30日以内**に、訴えをもって当該取締役の**解任**を請求できます（854条1項）。21-40-5、22-36-5 

ただし、総株主の議決権の**100分の3以上**の議決権又は発行済株式総数の**100分の3以上**の株式を**6ヶ月前**から引き続き有する株主でなければ請求をすることができません（非公開会社では、6ヶ月間の継続保有要件は不要です）。

(6) 取締役に欠員が生じた場合

① 旧取締役の職務執行

取締役が欠けた場合又は会社法・定款で定めた取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した取締役は、**新たに選任された取締役に就任**するまで、なお取締役としての権利義務を有することになります（346条1項）。21-40-2・3

② 一時取締役（仮取締役）

上記の場合、裁判所は、必要があると認めるときは、**利害関係人**の申立てにより、**一時的に取締役の職務を行うべき者**を選任することができます（346条2項）。

(7) 取締役の権限

取締役の権限は、会社の機関設計によって異なります。

① 取締役会非設置会社の場合

取締役会非設置会社では、定款に別段の定めがない限り、会社の業務執行は**各取締役**が行うことになります（348条1項）。ただし、取締役が2人以上いる場合には、定款に別段の定めがない限り、**取締役の過半数**をもって業務執行の意思決定をします（348条2項）。

また、取締役が2人以上いる場合であっても、各取締役が単

1 過去問チェック

監査役および監査委員が設置されていない株式会社の株主であって一定の数の株式を保有する株主は、取締役が法令違反行為を継続して行っているときには、直ちに当該取締役を解任する訴えを提起することができる。

→  (22-36-5)

2 参考

一時的に取締役の職務を行うべき者が株式会社の常務に属しない行為をする場合、裁判所の許可を得る必要はない。21-40-4

独で会社を代表するのが原則です（349条2項）。※3

② 取締役会設置会社の場合

個々の取締役は、取締役会の一構成員として決議に参加するだけで、独立に業務執行権や会社代表権を有するわけではなく、**代表取締役**が業務執行権や代表権を有します。図23-39-2

もっとも、**業務執行取締役**※4は、個々の業務執行権を有しています（2条15号かつこ書、363条1項2号）。

(8) 取締役の義務

① 善管注意義務・忠実義務

取締役と会社とは委任の関係に立ちますから（330条）、取締役はその職務を行うにあたり、会社に対して**善管注意義務**を負います（民法644条）。また、取締役は、会社に対して**忠実義務**を負います（355条）。※5

② 競業避止義務

取締役が会社の事業と競合する事業を行うと、会社のノウハウや顧客情報を奪われるおそれがあり、会社の利益を害する危険性が高いです。そこで、取締役は、自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引（競業取引）をしようとするときは、**株主総会**（取締役会設置会社の場合、**取締役会**）において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません（356条1項1号、365条1項）。図25-39-オ、元-40-5

また、取締役会設置会社の場合、競業取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を**取締役会**に報告しなければなりません（365条2項）。

③ 利益相反取引

取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引する場合（**直接取引**：356条1項2号）、又は、株式会社が取締役の個人的な債務を保証するなど取締役と株式会社が直接に取引をするわけではないが、取締役と株式会社との利益が相反する取引をする場合（**間接取引**：356条1項3号）、会社の利益を害する危険性が高いです。このような取引を**利益相反取引**といいます。※6

※3 参考

取締役会非設置会社の取締役は、代表取締役が他に選定されても、業務執行権は当然には消滅しない。図23-39-3

※4 用語

業務執行取締役：取締役会の決議によって会社の業務を執行する取締役として選定された者のこと。

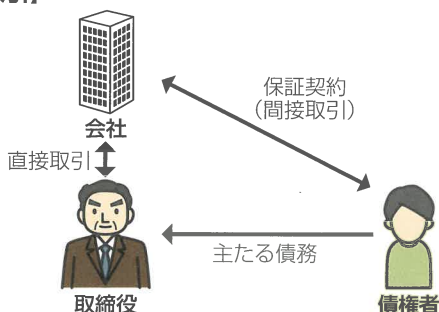
※5 重要判例

善管注意義務と忠実義務は、別個の義務ではない（最大判昭45.6.24）。

※6 参考

直接取引について会社の承認を得た場合には、民法108条1項（自己契約・双方代理の禁止）は適用されない（356条2項）。図19-39-2

【利益相反取引】



取締役は、利益相反取引をしようとするときは、**株主総会**（取締役会設置会社の場合、**取締役会**）において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません（356条1項2号・3号、365条1項）。**22-37-3** **※1**、25-39-ア・ウ

また、取締役会設置会社の場合、利益相反取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を**取締役会**に報告しなければなりません（365条2項）。**19-39-1**

なお、会社の承認の有無を問わず、利益相反取引が行われ会社に損害が生じた場合には、以下の者の**任務懈怠**^{けたい}が推定されることになります（423条3項）。

【任務懈怠の推定】

1	利益が相反する関係にある取締役・執行役
2	利益相反取引をすることを決定した取締役・執行役
3	利益相反取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役 25-39-3

(9) 取締役の報酬等

取締役の報酬等の額、具体的な算定方法又は報酬等の具体的な内容については、定款に当該事項の定めがあるときを除き、**株主総会決議**によって定めます（361条1項）。取締役の報酬等の決定は業務執行に係る事項ですが、取締役が自ら報酬を決定するのでは過大な報酬となるおそれが大きいことから、定款又は株主総会で決定するものとされています。**※2** **25-39-イ**

※1 過去問チェック

会社が取締役のために、当該取締役の住宅ローンの保証人となる場合には、取締役会の決定を要する。→**○**（22-37-3）

※2 法改正情報

令和元年の会社法改正により、①上場会社等において、取締役の個人別の報酬内容が株主総会で決定されない場合、取締役会は決定方針を定め概要等を開示しなければならない（361条7項）、②報酬として株式等を付与する場合、株主総会の決議事項にその上限等を加える（361条1項4号）、③上場会社が報酬として株式の発行等をする場合、金銭の払込み等は不要（361条1項3号、202条の2第1項1号）とされた。

4 取締役会

(1) 職務

取締役会とは、すべての取締役で組織される合議制の機関のことです。

取締役会の職務は、①**業務執行の決定**、②**個々の取締役の職務の執行の監督**、③**代表取締役の選定・解職**の3つです(362条2項)。

① 業務執行の決定

取締役会は、会社の日常業務(常務)の意思決定を**代表取締役**や**業務執行取締役**に委任することができます。図20-37-オ

しかし、以下のような特に会社にとって重要な事項は、代表取締役等に委任することができず、**取締役会**で決議しなければなりません(362条4項各号)。図20-37-オ、24-39-工

【取締役会で決議しなければならない事項】

1	重要な財産の処分・譲受け
2	多額の借財 図22-37-4 ※3
3	支配人その他の重要な使用人の選任・解任
4	支店その他の重要な組織の設置・変更・廃止 図22-37-5 ※4
5	募集社債に関する重要事項
6	株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な内部統制システムの整備構築 図20-37-イ
7	定款の定めに基づく役員等の会社に対する損害賠償責任の免除

② 個々の取締役の職務の執行の監督

代表取締役・業務執行取締役は、**3ヶ月に1回以上**、職務執行の状況を取締役会に報告しなければなりません(363条2項)。これは、取締役会を3ヶ月に1回以上開催する必要があることを意味します。図20-37-ア

③ 代表取締役の選定・解職

取締役会は監督や意思決定をする合議体ですから、そこでなされた意思決定の執行者として**代表取締役**が選定されます(362条3項)。

※3 過去問チェック

会社が事業拡大のために、銀行から多額の融資を受ける場合には、取締役会の決定を要する。→○(22-37-4)

※4 過去問チェック

会社が事業の見直しのために、支店を統廃合する場合には、取締役会の決定を要する。→○(22-37-5)

(2) 招集手続

① 招集権者

取締役会の招集権は、原則として、**各取締役**が有しています(366条1項本文)。もっとも、定款又は取締役会で**招集権者たる取締役**を定めることもできます(同ただし書)。**図**20-37
-ア **※1**、元-39-ア

また、招集権者と定められていない取締役であっても、招集請求をすることは可能です(366条2項・3項)。**※2**

② 招集通知

招集の通知方法にとくに制限はなく、口頭でも書面でも構いません。また、招集通知に議題を示す必要はありません。**図**元-39-イ

招集通知は、取締役会の**1週間前**に発しなければなりません。定款でこの期間を**短縮**することはできます(368条1項かつこ書)。**※3** **図**元-39-イ

③ 招集手続の省略

取締役(監査役設置会社では取締役及び監査役)の**全員の同意**があるときは、招集手続を省略することができます(368条2項)。

(3) 決議方法

① 議決権

取締役会の場合は、**1人**につき1議決権が認められます。株主の場合とは異なり、議決権の代理行使は許されません。

また、決議に**特別な利害関係**を有する取締役は、そもそも議決に加わることができません(369条2項)。**図**元-39-エ

② 決議要件

議決に加わることができる取締役の**過半数が出席**し、その出席取締役の**過半数で決定**します(369条1項)。この要件を定款で加重することはできますが、軽減することはできません。**図**元-39-ウ

③ 持ち回り決議

議決に加わることができる取締役全員が書面・電磁的記録により議案である提案に同意する意思表示をした場合には、その

※1 過去問チェック

取締役会は3ヶ月に1回以上招集しなければならないが、その招集権者を代表取締役とすることができる。→○(20-37-ア)

※2 参考

監査役が設置されている場合、監査役も、取締役の不正行為やそのおそれ、法令・定款違反の事実、著しく不当な事実があると認めるときは、取締役会を招集することができる(383条2項・3項)。

※3 参考

取締役会の招集通知は、各取締役に発しなければならない。監査役設置会社にあつては、各取締役および各監査役に発しなければならない(368条1項)。**図**元-39-イ

提案を可決した取締役会決議があったものとみなす旨を定款で定めることができます（370条）。これは、持ち回り決議を認めて、取締役会の開催の省略を許すものです。※4 21-37-4

④ 決議の瑕疵

取締役会決議の瑕疵については、株主総会決議のように特別の訴えの制度が用意されていませんから、一般原則により当然に無効となります。

(4) 取締役会議事録

① 備置き

取締役会が終了した後は、議事の経過の要領と結果について議事録を作成し、出席者が署名をし、会議終了日から10年間、本店に備え置かなければなりません（369条3項、371条1項）。

② 閲覧・謄写

株主は、権利行使のために必要があるときは、株式会社の営業時間内はいつでも（監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では裁判所の許可を得て）議事録の閲覧・謄写請求をすることができます（371条2項・3項）。20-36-5、22-36-1 ※5、24-38-4

また、会社債権者・親会社社員は、取締役の責任追及のために必要な場合に限り、裁判所の許可を得て、閲覧・謄写請求をすることができます（371条4項・5項）。20-36-2

③ 賛成の推定

取締役会の決議に参加した取締役は、議事録に異議をとどめなければ決議に賛成したものと推定されます（369条5項）。19-39-4、元-39-オ

(5) 特別取締役による取締役会決議

① 特別取締役とは何か

取締役の数が多く遠隔地にも取締役が常駐しているような大企業では、常務会と呼ばれるような形で少人数の取締役で重要事項を迅速に意思決定することが行われてきました。会社法は、これを特別取締役による取締役会決議として制度化しています（373条）。

※4 参考

監査役設置会社において監査役が異議を述べた場合、持ち回り決議は許されない（370条かつこ書）。21-37-4

※5 過去問チェック

監査役または監査委員が設置されている株式会社の株主は、取締役の任務懈怠を理由とする責任追及を行うために、当該会社に対して、営業時間内であれば、いつでも取締役会議事録の閲覧および謄写を請求することができる。→×（22-36-1）

② 要件

特別取締役をおくためには、**取締役の数が6人以上**であり、かつ、**社外取締役※¹**が**1人以上**であることが必要です。なお、特別取締役は、取締役会で選定されます。※² 図19-38-2

③ 員数

特別取締役は、**3人以上**であることが必要です。

④ 決議事項

迅速性が要求される**重要な財産の処分・譲受け、多額の借財**(362条4項1号・2号)についてのみ、特別取締役による取締役会で決議できます。※³

5 代表取締役

(1) 選定

代表取締役とは、会社の業務を執行し、対外的に会社を代表する取締役のことです。

取締役会設置会社の場合、代表取締役は、**取締役会の決議**で取締役の中から選定しなければなりません(362条2項3号・3項)。図18-40-5

これに対して、取締役会非設置会社では、**定款、定款の定めに基づく取締役の互選**又は**株主総会の決議**によって取締役の中から選定することができます(349条3項)。

(2) 員数

代表取締役の人数に制限はなく、1人でも複数でも構いません。

(3) 終任

代表取締役は、取締役であることが前提ですから、取締役の地位を失った場合には、当然に代表取締役の地位も失います。ただし、代表取締役の地位を失ったからといって、当然に取締役の地位を失うわけではありません。

(4) 権限

代表取締役は、会社の業務に関する一切の**裁判上又は裁判外**の行為をする包括的代表権を有し(349条4項)、これを定款等で制限しても、**善意の第三者**に対抗することができません(349

※1 用語

社外取締役：株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人ではなく、かつ、その就任の前10年間にこれらの役職についたことがないことなどの要件を満たすものこと(2条15号)。図23-39-4、30-39-1

※2 参考

指名委員会等設置会社は、特別取締役をおくことができない。図24-39-オ

※3 参考

特別取締役は、重要な財産の処分・譲受け、多額の借財以外についての通常の取締役会決議にも参加することができる。図23-39-5

※4 重要判例

代表取締役が代表権を濫用した場合、民法107条により、相手方が代表取締役の意図につき悪意又は有過失のときは、会社は当該代表取締役の代表行為の効力を否定することができる(最判昭38.9.5)。

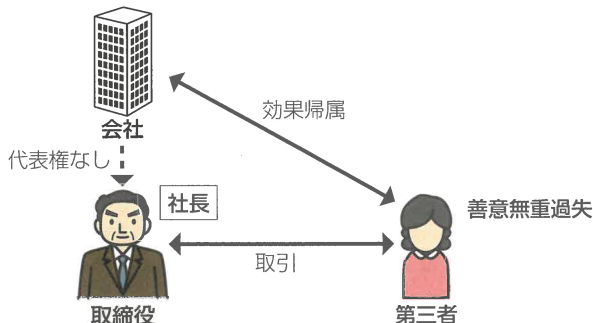
条5項)。**※4** **※5**

(5) 表見代表取締役

① 表見代表取締役とは何か

表見代表取締役とは、代表権がないにもかかわらず、社長・副社長その他会社の代表権を有すると認めるべき名称が付された取締役のことです。そして、表見代表取締役が**善意の第三者**との間でした行為については、会社が責任を負うことになります(354条)。

【表見代表取締役】



② 要件

この表見代表取締役制度が適用されるための要件は、以下の3つです(354条)。

【表見代表取締役の要件】

1	会社を代表する権限を有するものと認められる名称があること ※6
2	会社がその名称を付したこと ※7
3	相手方が善意であること ※8

6 会計参与

会計参与とは、取締役と共同して計算書類 **※9** などを作成する機関のことです(374条1項)。これは、会計の専門家である会計参与が取締役と共同して計算書類を作成することで、計算書類の正確性を高めようとするものです。図19-38-4 **※10**

会計参与は、会計に関する専門性を備えていなければならないことから、**公認会計士・監査法人又は税理士・税理士法人**で

※5 参考

代表取締役は、取締役会決議に基づいて、代表権の一部を他の取締役に移譲することはできない。図20-37-エ

※6 具体例をイメージ

例えば、社長・副社長・頭取・総裁・専務・常務といった名称・肩書きを持っていることなどである。

※7 具体例をイメージ

例えば、会社が代表者でない者に代表者であるかのような名称使用を明示的に認めた場合や、黙認していた場合などである。

※8 重要判例

条文上は「善意」としか規定されていないが、善意無重過失であることが要求される(最判昭52.10.14)。

※9 用語

計算書類：貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表のこと(435条2項、会社計算規則59条1項)。

※10 過去問チェック

会計参与は、会計監査人とは異なる会社役員であり、取締役と共同して計算書類等を作成する。→○(19-38-4)

なければならないとされています（333条1項）。

7 監査役・監査役会

(1) 監査役

① 監査役とは何か

監査役とは、取締役や会計参与の職務の執行が適法になされているかを監査する機関のことです。監査役は、定款で特に定めのない限り、業務監査権限と会計監査権限の両方を有しています。^{※1}

② 資格

監査役は、当該会社とその子会社の**取締役・使用人**、子会社の**会計参与・執行役**を兼ねることはできません（335条2項）。監査する者と監査される者が同一では、適正な監査は期待できないからです。

③ 員数

監査役会を設置しない会社であれば、**1人**でも足りませんが、監査役会設置会社では**3人以上**必要であり、そのうち半数以上は社外監査役^{※2}でなければなりません（335条3項）。 3-39-イ

④ 選任

監査役は、取締役と同じく、**株主総会の普通決議**によって選任されます（329条1項、341条）。 27-39-1

⑤ 終任

監査役の任期は**4年**であり（336条1項）、取締役のように任期を定款や株主総会決議で短縮することはできません。ただし、非公開会社では定款で**10年に伸長**できるという点は、取締役と同様です（336条2項）。

また、株主総会で監査役の解任決議をする場合、取締役とは異なり、**株主総会の特別決議**が必要となります（339条1項、309条2項7号）。 27-39-4

⑥ 権限・職務

監査役は、以下のような権限・職務を有しています。

※1 参考

非公開会社であって監査役会・会計監査人が置かれていない会社では、定款で監査役の職務を会計監査の範囲に限定することができる（389条1項）。 21-37-5

※2 用語

社外監査役：株式会社の監査役であって、その就任の前10年間に当該株式会社又はその子会社の取締役・会計参与・執行役・支配人その他の使用人となったことがないことなどの要件を満たすものこと（2条16号）。

【監査役の権限・職務】

調査権	①いつでも、取締役・会計参与等に対して事業の報告を求め、会社の業務・財産の状況を調査することができる（381条2項） ②必要があれば、子会社についても調査することができる（381条3項）
不正行為等の報告義務	取締役の不正行為、法令・定款違反を発見したときは、遅滞なく、取締役会（取締役会非設置会社では取締役）に報告をしなければならない（382条）
取締役会出席・意見陳述義務	取締役会に出席し、必要があれば意見を述べなければならない（383条1項本文）
株主総会への報告義務	取締役が株主総会に提出しようとする議案・書類等を調査し、法令・定款違反や著しく不当な事実を発見した場合には、株主総会に報告をしなければならない（384条）
会社・取締役間の訴訟の会社代表	会社と取締役の間の訴訟については、監査役が会社を代表する（386条1項）  20-37-ウ  3、25-39-エ

(2) 監査役会

監査役会とは、すべての監査役で組織される合議制の機関のことです。

監査役会の職務は、①**監査報告の作成**、②**常勤の監査役の選定・解職**、③**監査の方針、会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定**の3つです（390条2項本文）。

8 会計監査人

会計監査人とは、計算書類の作成が適正になされているかを監査する機関のことです。会計監査人は、監査役と異なり、業務監査権限を有しておらず、会計監査権限のみ有しています。

会計監査人は、特に会計に関する専門性を備えていなければならないことから、**公認会計士**又は**監査法人**でなければなりません（337条1項）。

*3 過去問チェック

代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上の権限を有するため、取締役の義務違反により会社に損害が生じた場合に、当該取締役に対する責任追及のための訴訟を提起する。
→×（20-37-ウ）

*4 参考

監査役会で監査役の職務の執行に関する事項を決定したとしても、個々の監査役の権限の行使が妨げられるわけではない（390条2項ただし書）。

*5 引っかけ注意!



会計参与と異なり、税理士又は税理士法人は、会計監査人になることができません。

9 指名委員会等設置会社

指名委員会等設置会社とは、指名委員会・報酬委員会・監査委員会の3委員会を置く株式会社のことです（2条12号）。※1

指名委員会等設置会社の各委員会は、**3名以上**の取締役で構成されます（400条1項）。また、各委員会の委員の過半数は**社外取締役**でなければなりません（400条3項）。📖 3-39-才

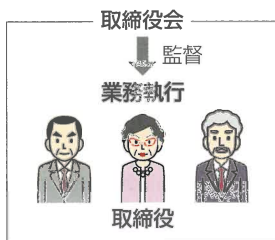
なお、各委員会の権限の内容は、以下のとおりです。

【各委員会の権限】

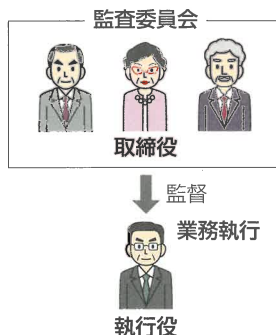
指名委員会	株主総会に提出する取締役・会計参与の選任・解任に関する議案の内容の決定
報酬委員会	取締役・執行役・会計参与の個人別の報酬の決定
監査委員会	取締役・執行役・会計参与の職務の執行の監査

指名委員会等設置会社は、業務執行に対する監督の強化を図るため、業務執行と監督を分離しています。具体的には、会社の業務執行の決定を取締役とは別に選定された**執行役**が行い、**取締役（監査委員会）**がそれを監督するという仕組みになっています。※2

【通常の株式会社】



【指名委員会等設置会社】



※1 法改正情報

平成26年の会社法改正により、委員会設置会社の名称が、指名委員会等設置会社に変更された。

※2 参考

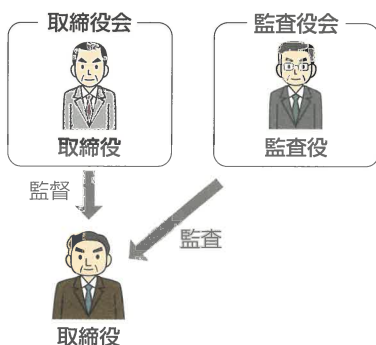
執行役は、取締役会決議で選任される（402条2項）。📖 19-38-3

10 監査等委員会設置会社

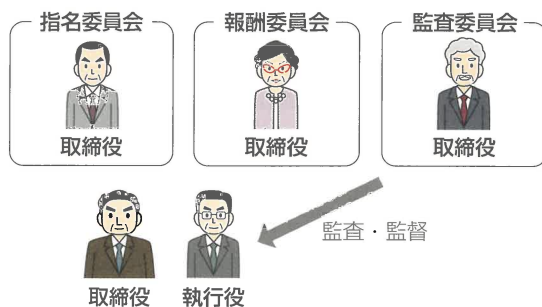
監査等委員会設置会社とは、監査等委員会を置く株式会社のことです（2条11号の2）。

監査役（会）設置会社は、監査役（会）が取締役の業務執行を監査し、取締役会が取締役の業務執行を監督するものですが、取締役とは別に監査役（会）を設置するのは負担となるため、現実にはあまり利用されてきませんでした。他方、指名委員会等設置会社は、取締役で構成される監査委員会が取締役・執行役の業務執行を監査・監督するものであり、取締役とは別に監査役（会）を設置する必要はありませんが、指名委員会・報酬委員会を設置することへの抵抗感が強く、やはり現実にはあまり利用されてきませんでした。そこで、その中間的な形態として、自ら業務を執行しない取締役で構成される監査等委員会が取締役の業務執行を監査・監督する監査等委員会設置会社の制度が新設されました。

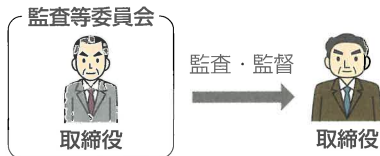
【監査役（会）設置会社の監査・監督】



【指名委員会等設置会社の監査・監督】



【監査等委員会設置会社の監査・監督】



11 役員等の責任 ※1

(1) 会社に対する責任

① 責任の内容

役員等 ※2 は、その**任務を怠ったとき**は、会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います（423条1項）。

もっとも、役員等が**注意を怠らなかったことを証明**した場合には、損害賠償責任を免れることができるのが原則です（過失責任）。

ただし、会社法上、無過失責任とされている場合もあります。まとめると、以下の表のようになります。

【役員等の任務懈怠責任】

競業取引に関する責任			過失責任 ※3
利益相反取引に関する責任	直接取引	原則	過失責任
		自己のために取引した場合	無過失責任 (428条 1 項)
	間接取引		過失責任
利益供与に関する責任 (120条 4 項本文)	原則		過失責任 (120条 4 項ただし書)
	自ら利益供与をした取締役・執行役		無過失責任 (120条 4 項ただし書かつこ書)
剰余金の配当に関する責任 (462条 1 項)			過失責任 (462条 2 項)

② 責任の免除・制限

役員等の任務懈怠責任は、以下のような場合に免除又は制限することができます。

※1 参考

役員等が株式会社に對して生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とされる（430条）。 19-39-3

※2 用語

役員等：取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人のこと（423条1項）。

※3 参考

会社の承認を受けないうで競業取引をした場合、取締役が競業取引によって得た利益が会社に生じた損害と推定されるから（423条2項）、会社は、損害賠償を請求する際に損害額を証明する必要はない。

【役員等の任務懈怠責任の免除・制限】

株主の同意による免除	役員等の会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意により免除することができる（424条）※4
株主総会の特別決議による一部免除	役員等が職務を行うにつき善意・無重過失である場合、株主総会の特別決議により責任の一部を免除することができる（425条1項、309条2項8号）※5
取締役等による免除に関する定款の定め	役員等が職務を行うにつき善意・無重過失の場合において、特に必要と認めるときは、取締役の過半数の同意（取締役会設置会社では取締役会決議）によって、取締役の責任を免除することができる旨を定款で定めておくことができる（426条1項）
責任限定契約	会社は、非業務執行取締役・監査役・会計参与・会計監査人がその職務を行うにつき善意・無重過失であれば、定款で定めた額の範囲であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれかの高い額を限度とする契約（責任限定契約）を締結できる旨を定款で定めておくことができる（427条1項）

（2）第三者に対する責任

① 責任の内容

役員等は会社以外の第三者とは直接の法律関係を持たないので、役員等の行為によって第三者が損害を受けた場合、不法行為責任（民法709条）を追及されることはあっても、それ以外の責任を追及される立場にはありません。※6

しかし、役員等の行為は第三者に重大な影響を与えることが多いことから、第三者の保護を厚くする必要があります。

そこで、役員等がその職務を行うについて**悪意又は重大な過失**があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うものとされ（429条1項）、特別の法律上の責任が課せられています。※7

② 要件

役員等の第三者に対する責任が認められるためには悪意・重過失が必要ですが、それは損害についてではなく、**任務懈怠**について存在すればよいとされています（最大判昭44.11.26）。

また、役員等の行為によって、第三者が直接損害を被った場合（直接損害）であろうと、会社が損害を被った結果第三者が損害を被った場合（間接損害）であろうと、任務懈怠と第三者

※4 参考

違法な剰余金配当が行われた場合、総株主の同意があっても、分配可能額の限度でしか免除することができない。

※5 参考

取締役が自己のために利益相反取引（直接取引）を行った場合、株主総会の特別決議によっても一部免除をすることができない（428条2項）。
 図19-39-5

※6 重要判例

429条1項に基づく責任と民法709条に基づく不法行為責任は併存するので、第三者は、不法行為に基づく損害賠償請求をすることもできる（最大判昭44.11.26）。

※7 よくある質問



Q 役員等の第三者に対する損害賠償責任は、総株主の同意によって免除することはできないんですか？



A 役員等の第三者に対する損害賠償責任は、総株主の同意によって免除することはできません。なぜなら、損害を受けたのは株主ではなく第三者であり、株主が勝手に損害賠償しなくてよいとしてしまうことは、不当に第三者を害することになるからです。

の損害との間に**相当因果関係**が認められる限り、役員等は第三者に対して損害賠償責任を負います（最大判昭44.11.26）。

③ 責任を負う取締役

429条1項に基づく損害賠償責任を負うかどうかが問題となった取締役としては、以下のようなものがあります。

【429条1項に基づく損害賠償責任を負う取締役】

名目 取締役	非常勤のいわゆる社外重役として名目的に取締役就任しているにすぎない者でも、429条1項に基づく損害賠償責任を負われる場合がある（最判昭55.3.18）
表見 取締役	適法に選任されていないにもかかわらず取締役として登記されている者は、取締役でないことを善意の第三者に対抗できないため（908条2項）、429条1項に基づく損害賠償責任を負う（最判昭47.6.15）
退任 取締役	取締役を退任したにもかかわらず退任登記をしていなかった者は、退任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情が存在する場合に限り、429条1項に基づく損害賠償責任を負う（最判昭62.4.16）

12 株主の監督是正権

株式会社においては所有と経営の分離がなされていることから、取締役の行為は、株主ではなく取締役会や監査役などによって監督されるのが原則です。しかし、取締役や監査役は株主総会により多数決で選任されるものである以上、少数株主の利益が害されるおそれがあります。

そこで、個々の株主にも、取締役の行為の**監督是正権**が付与されています。具体的には、以下のようなものがあります。

(1) 取締役の違法行為の差止め

取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他の法令・定款違反の行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって会社に**著しい損害**が生じるおそれがあるときは、その行為の差止めを請求することができます（360条1項）。22-36-3 1、24-38-2

もっとも、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では、**回復することができない損害**が生じるお

※1 過去問チェック

監査役および監査委員が設置されていない株式会社の株主は、取締役の法令違反行為によって、当該会社に著しい損害が生じるおそれがあるときには、当該取締役に対して当該行為をやめることを請求することができる。→○(22-36-3)

それがあるときに限定されます（360条3項）。

差止め請求をすることができるのは、公開会社では**6ヶ月前**から引き続き株式を保有する株主であり、非公開会社では株主であれば保有期間の制限はありません（360条1項・2項）。※2

（2）株主代表訴訟

① 株主代表訴訟とは何か

役員間のなれ合い等から、会社によって役員等の責任追及が行なわれないことが考えられます。そこで、株主が会社に代わって役員等の責任を追及する制度である**株主代表訴訟**が認められています（847条）。

株主代表訴訟を提起することができるのは、公開会社では**6ヶ月前**から引き続き株式を保有する株主であり、非公開会社では保有期間の制限はありません（847条1項・2項）。図元-38-5

② 手続

株主代表訴訟を提起する場合、原則として、まず**書面**で会社に対して役員等の責任を追及する訴えを提起するように請求しなければなりません（847条1項本文）。そして、会社が当該請求があった日から**60日以内**に訴えを提起しないときは、当該株主は代表訴訟を提起することができます（847条3項）。※3

図22-36-4 ※4

ただし、この60日の期間の経過により会社に**回復することができない損害**を生じるおそれがある場合には、株主は、上記の手続を経ることなく、直ちに代表訴訟を提起することができます（847条5項）。

（3）業務執行検査役の調査

会社の業務執行に関し、不正の行為、法令・定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由がある場合に、総株主の議決権の**100分の3以上**の議決権を有する株主又は発行済株式数（自己株式を除く）の**100分の3以上**の数の株式を有する株主は、株式会社の業務・財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、**検査役の選任**の申立てをすることができます（358条1項）。図22-36-2 ※5

※2 参考

監査役も、取締役の違法行為の差止めを請求することができる（385条）。

※3 参考

株主が自己もしくは他人の不正な利益を図る、又は会社に損害を加える目的を有する場合には、株主代表訴訟を提起することができない（847条1項ただし書）。

※4 過去問チェック

監査役および監査委員が設置されていない株式会社の株主は、取締役の行為に法令に違反する重大な事実があるときには、当該会社を代表して、直ちに責任追及の訴えを提起することができる。→×（22-36-4）

※5 過去問チェック

監査役または監査委員が設置されている株式会社の株主であって一定の数の株式を保有する株主は、当該会社の業務の執行に関し、法令に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには、当該会社の業務および財産の状況を調査させるために、検査役の選任を監査役または監査委員に請求することができる。→×（22-36-2）

選任された検査役は、その職務を行うため必要があるときは、子会社の業務・財産状況を調査することができ（358条4項）、調査の結果を裁判所に報告します（358条5項）。そして、裁判所は、必要があると認めるときは、取締役に対して、一定の期間内に**株主総会を招集**すること、調査の結果を**株主に通知**することを命じなければなりません（359条1項）。

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ **1** すべての株式会社に必要な機関は、株主総会と1人以上の取締役である。
- ☐ ☐ ☐ **2** 取締役会設置会社では、株主総会は、会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
- ☐ ☐ ☐ **3** 株主総会の場合、原則として1株につき1議決権が認められるが、取締役会の場合、1人につき1議決権が認められる。
- ☐ ☐ ☐ **4** 役員等がその職務を行うについて軽過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

解答

- 1** ○（295条、326条1項） **2** ×取締役会設置会社では、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる（295条2項）。
- 3** ○（308条1項） **4** ×悪意又は重大な過失が必要である（429条1項）。



学習のPOINT

株式会社においては、株主は間接有限責任しか負わないため、会社債権者保護のため会社財産を確保する必要があります。そこで、会社法は、計算に関する規定を多数おいています。

1 会計帳簿

(1) 会計帳簿とは何か

会計帳簿とは、一定時期における会社の財産及びその価額並びに取引その他財産に影響を及ぼすべき事項を記載・記録する帳簿のことです。

(2) 作成・保存

株式会社は、**法務省令**で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければなりません（432条1項）。

また、会計帳簿の閉鎖の時から**10年間**、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければなりません（432条2項）。

(3) 閲覧・謄写請求

総株主の議決権の**100分の3以上**の議決権を有する株主又は発行済株式の**100分の3以上**の数の株式を有する株主は、株式会社の**営業時間内**は、いつでも、会計帳簿の閲覧・謄写を請求することができます（433条1項）。**例**20-36-3、24-38-5 **※1**、元-38-2

株主が監督は正権を適切に行使するためには、会社の業務・財産の状況を把握する必要があることから、会計帳簿閲覧・謄写請求権が認められていますが、会社の内部情報を知ろうとする者に濫用されるおそれがあることから、少数株主権とされています。

#1 過去問チェック

総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、その権利を行使するために必要があるときには、裁判所の許可を得て、会計帳簿の閲覧を請求することができます。→
×（24-38-5）

2 資本金制度

(1) 資本金とは何か

株主が間接有限責任しか負わないことから、会社の債権者は会社自体の財産からしか弁済を受けられないことになり、会社の財産を確保しておくことが強く要請されます。

そこで、株式会社は**資本金**として一定の額を定めておき、その額に見合うだけの財産を確保しておくべきであるとする資本金制度が採用されています。イメージとしては、資本金というコップを会社財産という水で満たしておかなければならないといった感じです。※1 ※2

資本金制度については、以下のような原則がとられています。

【資本原則】

資本維持の原則	資本金の額に相当する財産が現実には会社に保有されていなければならない
資本不変の原則	資本金の額は自由に増減させることができない

(2) 資本金の額

資本金の額は、原則として、株主が会社に出資した財産の総額です（445条1項）。

もっとも、株主が出資をした総額の**2分の1**を超えない額は、資本金として計上しないことができます（445条2項）。ただし、資本金として計上しない額は、**資本準備金**として計上しなければなりません（445条3項）。☞26-37-ア ※3、28-37-オ

そして、後に会社の財産が資本金よりも少なくなった場合には、資本準備金から資本金を補填することとされています。

(3) 資本金の額の減少に関する規制

資本金の額を減少させるためには、原則として、**株主総会の特別決議**を経なければなりません（447条1項、309条2項9号）。また、会社債権者保護のために、会社債権者に**異議**を述べる機会を与え、異議を述べた債権者には、債務の弁済等をしなければなりません（449条）。

もっとも、以下の場合には、例外的に株主総会の特別決議が

※1 参考

かつての最低資本金制度（1000万円以上）は廃止されている。☞29-40-オ

※2 参考

資本金は、登記及び貸借対照表によって公示されるが（911条3項5号、計算規則76条2項1号）、定款に記載・記録されるわけではない。

※3 過去問チェック

株主となる者が設立時発行株式と引換えに払込み、または給付した財産の額は、その全額を資本金に計上することは要せず、その額の2分の1を超えない額を資本準備金として計上することができる。→○（26-37-ア）

要求されません。

【株主総会の特別決議が不要な場合】

株主総会の普通決議で 足りる場合	①定時株主総会で欠損を填補するために資本金の額の減少をする場合（309条2項9号かつこ書、447条1項） ②剰余金の額を減少させて資本金の額を増加させる場合（450条1項、309条1項） 圖22-37-2 ※4
取締役の決定（取締役会設置会社では取締役会決議）で足りる場合	株式の発行と同時に資本金の額を減少させる場合において、効力発生日後の資本金の額が効力発生日前の資本金の額を下回らないとき（447条3項）

3 剰余金の配当

（1）剰余金の配当とは何か

剰余金の配当とは、会社が株主に会社財産を分配することです。

剰余金の配当は、確定した計算書類及びこれに準ずる計算書類を基礎に、同一事業年度内に何度でも行うことができます。

圖23-40-1

（2）手続

① 原則

株式会社は、剰余金の配当をしようとするときは、その都度、**株主総会の普通決議**によって、配当財産の種類を定めなければなりません（454条1項、309条1項）。※5

② 現物配当

配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合には、**株主総会の特別決議**が必要となります（454条4項、309条2項10号）。圖23-40-4

③ 中間配当

取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り、**取締役会決議**により剰余金の配当（中間配当）をすることができます旨を定款で定めることができます（454条5項前段）。

圖20-38-ウ

※4 過去問チェック

会社が資本金を増加するために、剰余金を減少させる場合には、取締役会の決定で足りる。→×（22-37-2）

※5 参考

当該会社の株式・新株予約権・社債を配当財産とすることはできない（454条1項1号、107条2項2号ホかつこ書）。圖20-38-イ、30-40-5、3-40-イ

④ 会計監査人設置会社の特例

会計監査人設置会社であり、かつ、監査役会設置会社である会社が取締役（監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員以外の取締役）の任期を1年以下と定めた場合は、株主総会の承認に代えて、**取締役会**で剰余金の配当を決定することができます（459条1項）。23-40-3、3-40-工

(3) 財源規制

① 純資産額

純資産 1 の額が**300万円**を下回る場合には、剰余金の配当をすることができません（458条）。20-38-工、3-40-ウ

② 分配可能額

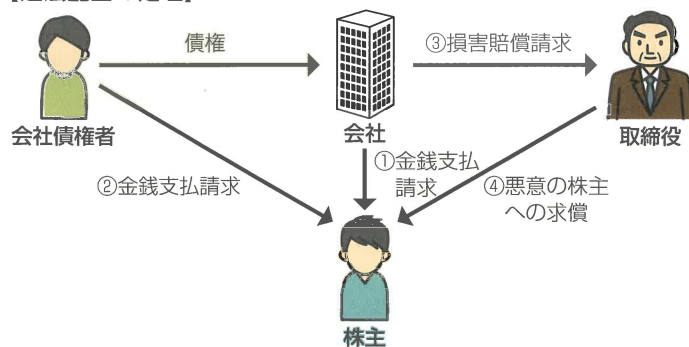
剰余金の配当により株主に交付される金銭等の帳簿価額の総額は、剰余金の配当が効力を生ずる日における**分配可能額**を超えてはならないとされています（461条1項8号）。20-38-ア、3-40-オ

これに反して剰余金の配当がなされた場合、違法配当となります。

(4) 違法配当

違法配当がなされた場合、以下のように処理されることになります。

【違法配当の処理】



① 会社の請求権

会社は、違法配当を受けた**株主**に対し、交付を受けた金銭等

1 用語

純資産：資産から負債を差し引いたもののこと。

の帳簿価額に相当する金銭を支払うよう請求することができます（462条1項）。これは、株主が善意であっても悪意であっても同様です。図30-40-3

② 債権者の請求権

会社債権者は、違法配当を受けた**株主**に対し、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払うよう請求することができます（463条2項）。

③ 取締役に対する損害賠償請求権

会社は、**取締役**に対して損害賠償請求をすることによって、その損失を填補することができます（423条1項、462条1項6号）。

④ 取締役から悪意の株主への求償

取締役が会社に対して損害賠償をした場合、取締役は、**悪意の株主**に対して求償権を行使することができます（463条1項）。

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ **1** 株主は、その有する議決権数や株式数にかかわらず、株式会社の営業時間内は、いつでも、会計帳簿の閲覧・謄写を請求することができる。
- ☐ ☐ ☐ **2** 資本金の額は、原則として、株主が会社に出資した財産の総額である。
- ☐ ☐ ☐ **3** 株式会社は、剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の特別決議によって、配当財産の種類を定めなければならないのが原則である。

解答

-  **×** 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主又は発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主に限られる（433条1項）。 **2**  （445条1項）
-  **×** 株主総会の普通決議である（454条1項、309条1項）。

学習のPOINT



持分会社については、株式会社と対比しつつ学習すると効率的です。ただ、出題頻度は低いので、時間に余裕のある人だけ一読しておけば十分でしょう。

1 持分会社の設立

(1) 設立手続

① 定款の作成

持分会社を設立するには、その社員になろうとする者が**定款**を作成し、その全員がこれに**署名**し、又は**記名押印**しなければなりません（575条1項）。

もっとも、公証人の認証は不要です。

② 出資の履行

出資の履行については、持分会社の種類によって、以下ののような違いがあります。

【持分会社における出資の履行】

	合名会社	合資会社	合同会社
出資の方法 図22-39-1	信用・労務の出資も可能	無限責任社員は信用・労務の出資も可能だが、有限責任社員は金銭等の財産の出資に限られる	金銭等の財産の出資に限られる
出資の履行時期 図18-40-3	制限なし		設立登記時までに履行しなければならない（578条）

③ 設立登記

持分会社は、その本店の所在地において**設立の登記**をすることによって成立します（579条）。

※1 過去問チェック

持分会社の無限責任社員は、株式会社の株主とは異なり、金銭出資や現物出資にかかわらず、労務出資や信用出資の方法が認められている。→
○（22-39-1）

※2 過去問チェック

合資会社の有限責任社員は、定款記載の出資額までしか責任を負わないため、有限責任社員となる時点で出資金額の履行が要求されている。→
×（18-40-3）

(2) 設立の瑕疵

① 設立無効

株式会社の場合と同様に、設立手続に瑕疵があった場合には、設立は**無効**となります。

② 設立取消し

持分会社の設立については、株式会社と異なり、制限行為能力、錯誤、詐欺・強迫や詐害行為を理由とする**設立取消しの訴え**が認められています（832条）。

2 持分

(1) 持分とは何か

持分とは、持分会社の社員たる地位のことです。

持分会社の持分は、株式会社の株式とは異なり、1人1持分であって、細分化されたものではなく、内容が均一化されたものでもありません。図22-39-2、28-40-U

(2) 持分の譲渡

持分会社の社員は、**他の社員の全員の承諾**がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができません（585条1項）。

もっとも、業務を執行しない有限責任社員は、**業務を執行する社員の全員の承諾**があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができます（585条2項）。

3 持分会社の管理

(1) 業務執行権

持分会社の社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、各自で持分会社の**業務を執行**します（590条1項）。図18-40-5、22-39-3

株式会社では、所有と経営の分離が原則とされていましたが、持分会社では、所有と経営の一致が原則とされています。

(2) 代表権

業務を執行する社員は、原則として、各自が持分会社を**代表**します（599条1項本文）。図22-39-3

4 社員の加入及び退社

(1) 加入

合名会社・合資会社の社員の加入は、その社員に係る**定款の変更をした時**に効力が生じます（604条2項）。※1

これに対して、合同会社の社員の加入は、その社員に係る定款の変更に加えて、その社員が**払込み又は給付を完了した時**に効力が生じます（604条3項）。

(2) 退社

退社した社員は、原則として、その出資の種類を問わず、その**持分の払戻し**を受けることができます（611条1項）。図22-39-4

もっとも、退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、**従前の責任の範囲内**でこれを弁済する責任を負います（612条1項）。※2

※1 参考

持分会社が定款を変更するためには、原則として、総社員の同意が必要である（637条）。図22-39-5

※2 参考

退社の登記は對抗要件にすぎず、退社の効力自体は登記によって生ずるわけではない。図22-39-4

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ 1 持分会社の設立については、株式会社と異なり、制限行為能力、錯誤、詐欺・強迫や詐害行為を理由とする設立取消しの訴えが認められている。
- ☐ ☐ ☐ 2 持分会社の持分は、株式会社の株式と同様に、細分化され、内容が均一化されたものである。
- ☐ ☐ ☐ 3 持分会社の有限責任社員は、持分会社の業務を執行する権限を有しない。
- ☐ ☐ ☐ 4 持分会社を退社した社員は、原則として、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。

解答

1 ○（832条） 2 ×細分化されていないし、内容も均一化されていない。 3 ×有限責任社員であるか無限責任社員であるかを問わず、各自で持分会社の業務を執行する（590条1項）。 4 ○（611条1項）



学習のPOINT

組織再編は、①事業の譲渡、②組織変更、③合併、会社分割、株式交換・株式移転、株式交付の3つの類型に分けられます。③については、合併の手続を押さえてそれを他に応用すると効率的です。

1 事業の譲渡

(1) 事業の譲渡とは何か

事業の譲渡とは、商法総則のところで学習した営業譲渡と同じ意味です（P 591参照）。※3

事業を構成する債権・債務及び契約上の地位を移転しようとする場合、事業譲渡契約とは別にその契約上の相手方の同意を要する点で、会社分割とは異なります。21-39-A

(2) 手続

① 株主総会の承認決議

事業の全部の譲渡、事業の重要な一部の譲渡（譲渡する資産の帳簿価格が総資産額の5分の1を超える場合）、事業の全部の譲受けについては、原則として、**株主総会の特別決議**が必要です（467条1項、309条2項11号）。※4 21-39-E

もっとも、以下の場合には、例外的に株主総会の特別決議が要求されません。

【株主総会の特別決議が不要な場合】

略式事業譲渡	事業の譲渡の相手方が 特別支配会社 ※5である場合（468条1項）
簡易事業譲渡	譲受会社が対価として交付する財産の帳簿価格の合計額が 純資産額の5分の1以下 の場合（468条2項）

② 反対株主の株式買取請求権

事業の譲渡の承認決議前に反対の意思表示をし、かつ、承認決議に反対した株主は、原則として、**株式買取請求権**を行使することができます（469条1項）。

※3 参考

事業の全部の譲渡をした場合でも、当然に譲渡会社が解散するわけではない。

※4 参考

事業の重要な一部の譲受けについては、株主総会の特別決議は必要ない。21-39-O

※5 用語

特別支配会社：総株主の議決権の10分の9以上を保有している会社のこと。

③ 債権者保護手続

事業の譲渡については、債権者保護手続は**不要**です。なぜなら、事業の譲渡の場合、資産や債務が当然に移転されるわけではなく、会社の財産が変動するわけではないからです。

(3) 効果

事業の譲渡がなされると、営業譲渡がなされた場合と同様の効果が生じます（P 591、592参照）。

2 組織変更

(1) 組織変更とは何か

組織変更とは、株式会社がその組織を変更することにより持分会社となり、また、持分会社がその組織を変更することにより株式会社となることです（2条26号）。※1

(2) 手続

① 総株主の同意

組織変更をする会社は、組織変更計画を作成しなければならず、その効力発生日の前日までに、組織変更計画について**総株主の同意**を得なければなりません。※2

② 債権者保護手続

組織変更をする会社は、原則として、所定の事項を**官報に公告**し、かつ、会社が把握している債権者には**各別に催告**しなければなりません。ただし、公告方法として、定款に日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告を定めている場合は、各別の催告は必要ありません。

3 合併

(1) 合併とは何か

合併とは、2つ以上の会社が契約により1つに合わさることです。※3

合併には、**吸収合併**と**新設合併**の2種類があります。

① 吸収合併

吸収合併とは、会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社（A社）の権利義務の全部を、合併後存続す

※1 引っかけ注意!



合名会社が合資会社となる場合のよ

うに、持分会社間で組織を変更する場合は、組織変更とはならず、単なる持分会社の種類の変更となります（638条）。

※2 引っかけ注意!



組織変更をするには総株主の同意が

必要である以上、反対株主がいればそもそも組織変更自体をすることができませんから、反対株主の株式買取請求権は認められていません。

※3 参考

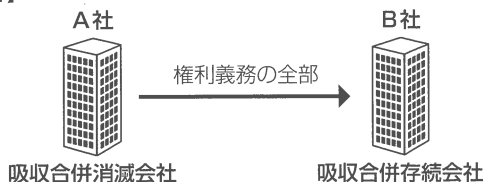
合併は、株式会社のみならず、持分会社（合名会社・合資会社・合同会社）も行うことができる。

24-40-1

る会社（B社）に承継させるもののことです（2条27号）。

18-39-オ、24-40-3

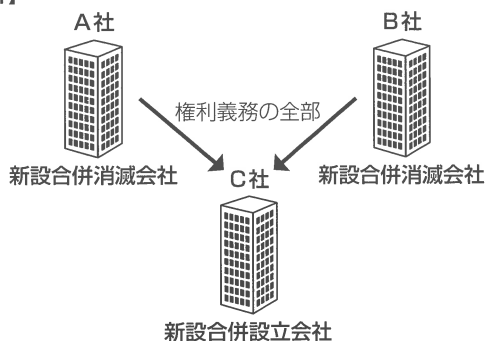
【吸収合併】



② 新設合併

新設合併とは、2つ以上の会社ができる合併であって、合併により消滅する会社（A社・B社）の権利義務の全部を、合併により設立する会社（C社）に承継させるもののことです（2条28号）。18-39-オ

【新設合併】



(2) 手続

合併の手続は、以下のような流れとなります。

【合併手続の流れ】

①合併契約	当事会社間で合併契約を締結する
②事前開示	当事会社は、合併契約の内容等を記載・記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置き、株主・債権者は、営業時間内はいつでも、閲覧・謄写を請求できる
③合併承認決議	当事会社は、 株主総会の特別決議 を経る ※1 ※2
④債権者保護 手続	当事会社は、所定の事項を官報に公告し、かつ、会社が把握している債権者には各別に催告する ※3
⑤事後開示	吸収合併存続会社・新設合併設立会社 は、合併の効力発生日後遅滞なく、所定の書面又は電磁的記録を本店に備え置き、株主・債権者は、営業時間内はいつでも、閲覧・謄写を請求できる ※4

(3) 効力発生時期

① 吸収合併

吸収合併存続会社は、**効力発生日**に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継します（750条1項、752条1項）。

② 新設合併

新設合併設立会社は、その**成立の日**に、新設合併消滅会社の権利義務を承継します（754条1項、756条1項）。

(4) 合併無効の訴え 18-39-工 ※5

会社の合併の無効は、各当事会社の株主・取締役等又は合併を承認しなかった債権者が、合併の効力が生じた日から**6ヶ月以内**に限り、**訴え**をもつてのみ主張することができます（828条1項7号・8号、2項7号・8号）。

そして、請求を認容する判決が確定したときは、その合併は**将来に向かって**効力を失います（839条）。

4 会社分割

(1) 会社分割とは何か

会社分割とは、1つの会社を2つ以上の会社に分けることです。 ※6

会社分割には、**吸収分割**と**新設分割**の2種類があります。

※1 参考

存続会社に比べて消滅会社の規模が著しく小さい場合（合併対価の額が存続会社の純資産額の5分の1以下の場合）、存続会社においては株主総会の特別決議を省略することができる（簡易合併：796条3項本文）。 18-39-ア

※2 参考

合併決議前に反対の意思表示をし、かつ、承認決議に反対した株主は、株式買取請求権を行使することができる。 18-39-ウ

※3 参考

公告方法として、定款に日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告を定めている場合は、各別の催告は要しない。 18-39-イ

※4 受験テクニック

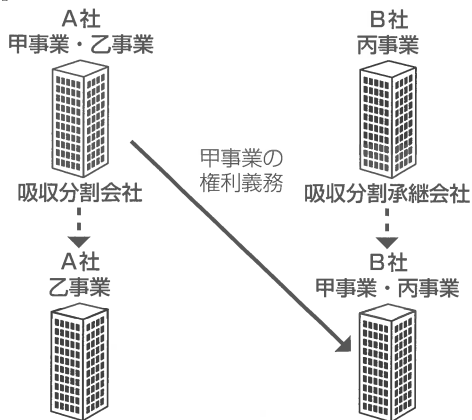


消滅してしまう会社に書面を備え置くことは物理上できませんので、吸収合併消滅会社や新設合併消滅会社は、関連書面等の備置きをする義務を負わないと覚えておきましょう。

① 吸収分割

吸収分割とは、**株式会社**又は**合同会社**（A社）が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、分割後他の会社（B社）に承継させることです（2条29号）。

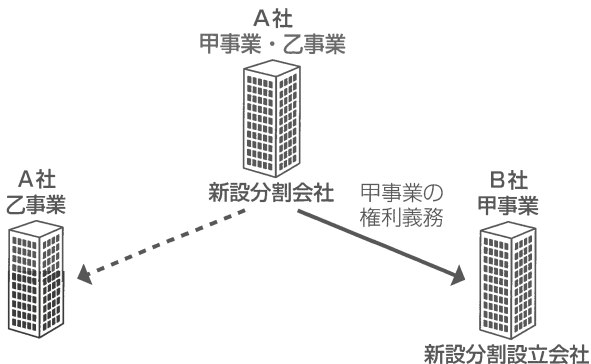
【吸収分割】



② 新設分割

新設分割とは、1又は2以上の**株式会社**又は**合同会社**（A社）が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、分割により設立する会社（B社）に承継させることです（2条30号）。

【新設分割】



(2) 手続

吸収分割会社（A社）については吸収合併消滅会社と、吸収

※5 過去問チェック

会社の合併が違法である場合に、各当事者会社の株主、取締役等、または合併を承認しなかった債権者は、その無効を合併無効の訴えによってのみ主張することができ、合併無効の判決が確定した場合には、将来に向かってその合併は無効となる。→○(18-39-エ)

※6 具体例をイメージ

例えば、複数の事業部門を有する会社（A社）が、そのうちの1つの事業部門を他の会社（B社）に承継させることで、不採算部門のカットや効率性の向上を図る場合などである。

分割承継会社（B社）については吸収合併存続会社と同様の手続が要求されています。

また、新設分割会社（A社）については新設合併消滅会社と、新設分割設立会社（B社）については新設合併設立会社と同様の手続が要求されています。

（3）効力発生時期

① 吸収分割

吸収分割承継会社は、**効力発生日**に、吸収分割会社の権利義務を承継します（759条1項、761条1項）。

② 新設分割

新設分割設立会社は、その**成立の日**に、新設分割会社の権利義務を承継します（764条1項、766条1項）。

（4）分割無効の訴え

会社分割についても、合併と同様に、**訴え**をもってのみ無効を主張することができます（828条9号・10号）。

5 株式交換・株式移転

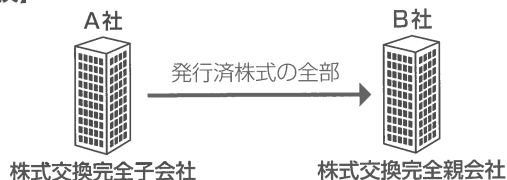
（1）株式交換・株式移転とは何か

株式交換・株式移転は、どちらも完全親子会社※1を簡易・円滑に創設するための手続です。

① 株式交換

株式交換とは、**株式会社**（A社）が、その発行済株式の全部を、他の**株式会社**又は**合同会社**（B社）に取得させることです（2条31号）。

【株式交換】



② 株式移転

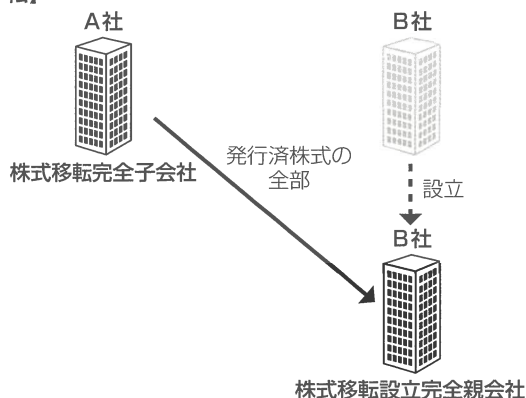
株式移転とは、1又は2以上の**株式会社**（A社）が、その発行済株式の全部を、新たに設立する**株式会社**（B社）に取得さ

※1 用語

完全親子会社：親会社の子会社の発行済株式のすべてを有しているという関係にあること。

せることです（2条32号）。

【株式移転】



(2) 手続

株式交換完全子会社（A社）については吸収合併消滅会社と、株式交換完全親会社（B社）については吸収合併存続会社と同様の手続が要求されています。

また、株式移転完全子会社（A社）については新設合併消滅会社と、株式移転設立完全親会社（B社）については新設合併設立会社と同様の手続が要求されています。

ただし、株式交換・株式移転により各当事会社の財産が変動するわけではないことから、原則として、債権者保護手続は**不要**とされています。

(3) 効力発生時期

① 株式交換

株式交換完全親会社は、**効力発生日**に、株式交換完全子会社の発行済株式（株式交換完全親会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く）の全部を取得します（769条1項、771条1項）。

② 株式移転

株式移転設立完全親会社は、その**成立の日**に、株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得します（774条1項）。

(4) 株式交換・株式移転無効の訴え

株式交換・株式移転についても、合併と同様に、**訴え**をもつ

てのみ無効を主張することができます（828条1項11号・12号）。

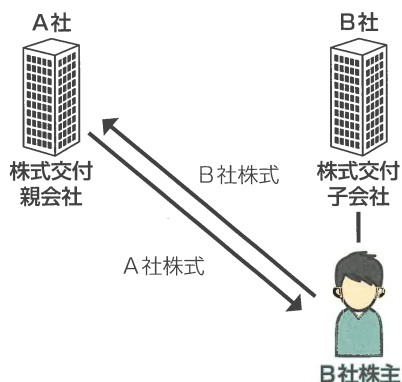
6 株式交付

(1) 株式交付とは何か

株式交付とは、**株式会社**（A社）が他の**株式会社**（B社）をその子会社とするために当該他の株式会社（B社）の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社（A社）の株式を交付することです（2条32号の2）。

株式会社が他の株式会社を子会社とする手続としては株式交換がありますが、株式交換の場合はその発行済株式の全部を取得させなければならず、一部のみを取得させて子会社とする手続が存在しなかったため、令和元年の会社法改正により、この株式交付の手続が創設されました。

【株式交付】



(2) 手続

株式交付親会社については、合併の場合と同様の手続が要求されています。

他方、**株式交付子会社**については、手続の規定は設けられていません。

(3) 効力発生時期

株式交付親会社は、**効力発生日**に、株式交付子会社の株式を譲り受けたものとされ（774条の11第1項）、株式交付子会社の

株式の譲渡人は、効力発生日に、株式交付親会社の株式の株主となります（774条の11第2項）。

（4）株式交付無効の訴え

・株式交付についても、合併と同様に、**訴え**をもってのみ無効を主張することができます（828条1項13号）。

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ **1** 事業の全部の譲渡については、原則として、株主総会の特別決議が必要である。
- ☐ ☐ ☐ **2** 吸収合併とは、2つ以上の会社ができる合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を、合併により設立する会社に承継させるもののことである。
- ☐ ☐ ☐ **3** 吸収分割や新設分割は、その会社の種類にかかわらず行うことができる。
- ☐ ☐ ☐ **4** 株式交換や株式移転を行う場合、債権者保護手続が必要である。

解答

- 1** ○（467条1項、309条2項11号） **2** ✕ 新設合併である（2条27号・28号）。
3 ✕ 吸収分割会社や新設分割会社となることができるのは、株式会社又は合同会社に限られる（2条29号・30号）。 **4** ✕ 原則として債権者保護手続は不要である。